

論強制性交罪違反意願之方法*

蔡聖偉**

摘要

我國刑法第16章在1999年經歷了一次具指標性意義的變革。其中一個重點，就是在第221條第1項刪除「至使不能抗拒」要素，並同時增訂了「其他違反被害人意願之方法」這個概括條款。本文認為，此處的被害人意願，應係指其是否從事性交的選擇，違反意願就是指其相關的選擇自由空間被剝奪。此外，概括條款在解釋上也必須受前導例式概念（強暴與脅迫）拘束，應該要具有剝奪被害人選擇自由的性質。但法條中所羅列的前導例示概念，業已窮舉了強制罪的所有強制手段，隨而在解釋「其他方法」時，就只能從強制手段以外的行為模式著眼。因此，應將概括條款理解成行為人「利用既存強制狀態」的情形。行為人利用此種狀態來遂行性交目的，本質上，與透過強制行為迫使被害人接受性交要求的情形相較，不法內涵上相當，均屬違反被害人意願。

關鍵詞：強制性交罪、違反意願性交罪、強暴、脅迫、違反意願、概括條款、乘機性交罪。

* 投稿日：2015年3月11日；接受刊登日：2015年12月22日。〔責任校對：向民潔〕。

本文為科技部專題研究計畫（計畫編號：NSC 101-2410-H-305-077）的研究成果，作者於此也要誠摯感謝審查人所提供的寶貴意見，讓本文能夠減少錯誤與不足之處。

** 國立臺北大學法律學院法律學系副教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/22206161.pdf>。



目次

壹、前言	五、與例示概念相當的強制手段？
貳、舊法「不能抗拒」要素所引發的問題	(一) 強暴與脅迫外的強制手段？
參、違反意願要素的體系定位及意義	(二) 不能抗拒或難以抗拒的方法？
肆、前導例示概念	六、本文立場：利用既存的強制狀態
一、強暴	(一) 與前導例示概念間的牽制關聯性
二、脅迫	(二) 利用既存的心理強制狀態
(一) 惡害內容的限縮？	(三) 利用既存的物理強制狀態
(二) 超自然的惡害？	(四) 與「乘機性交罪」的關係
伍、概括條款：其他違反被害人意願之方法	陸、結語
一、各種解釋建議	
二、保護意思決定不受干擾？	
三、未獲同意＝違反意願？	
四、陷於錯誤＝違反意願？	
(一) 與法益相關的錯誤	
(二) 其他的錯誤	

壹、前言

在1999年修法前，我國刑法典中的性犯罪都被放在「妨害風化」的招牌下。直到該次修法，才將原本的第16章一分為二，把第230條之前的規定移置「妨害性自主罪章」中，第230條至第236條則仍維持妨害風化罪章的名稱（第16章之1）。綜觀人類社會的演進史，無論是在歐洲、美洲還是亞洲，性犯罪都是先被定性成一種違反道德風俗的犯罪（*Delikte wider die Sittlichkeit*），直到整體社會對

於性的態度逐漸開放、轉變後，才會把強制性交猥褻罪看作是一種侵害自由（性自主決定權）的犯罪。這可說是各國性刑法的制式發展路線，在德國刑法典中，性犯罪的不法定性也曾經搖擺於侵害整體利益與侵害個人利益之間，最早規定在該法第13章「違反倫理道德的重罪與輕罪」（*Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit*）¹，經歷數十年的社會變遷後，1974年生效的第4次刑法修正案才將該章的章名改成「違反性自主決定的犯罪」（*Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung*）²。

雖然1999年修改刑法第16章章名的部分獲得一致的肯定，但學界對於具體條文的修訂，尤其是刑法第221條第1項（強制性交罪³）構成要件的描述方式，卻有兩極化的評價。有將之稱為「一段黑暗的刑事法史」⁴，但也有學者相反地認為，我國現行法將「違反被害人意願」加入構成要件中，是「正確、周延而且進步的立法；即便是德國立法也未能及」⁵。究竟應如何評價該次的修

1 也就是將之理解為風化犯罪（*Sittlichkeitsdelikte*），重在相關行為侵害了一般人在性方面的羞恥感及道德感，僅參閱Hans Welzel, *Das Deutsche Strafrecht*, 11. Aufl., 1969, S. 431.

2 關於德國性刑法歷史沿革的詳細介紹，可參閱Klaus Laubenthal, *Handbuch Sexualstraftaten, Die Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung*, 2012, Rn. 11-93.

3 該次修法刪除了舊法強姦罪中的「至使不能抗拒」要素，另外加入「其他違反被害人意願之方法」這個概括條款。修法後，文獻上咸將本罪改稱為「強制性交罪」，最高法院近年來則經常使用「違反意願性交罪」的稱呼。由於修法所新增的概括條款是否須具強制性質仍有爭論（詳見下文伍、），違反意願性交罪可算是較為中性且完全合乎法條文字的稱謂。有文獻基於此理由質疑「強制性交罪」這個名稱的妥當性，如甘添貴，*刑法各論（下）*，2版，頁237（2013年）。但若依照本文所提出的解釋建議（利用既存的強制狀態，見後文伍、六、），概括條款所掌握的情形便仍具妨害自由（強制）的性質，因此下文還是沿用國內文獻中的慣常用語：強制性交罪。

4 語見黃榮堅，2010年刑事法發展回顧：慾望年代，慾望刑法？，*臺大法學論叢*，40卷特刊，頁1832（2011年）。

5 語見徐偉群，需要翻轉的不是法律，是法界的知識狀態——強制性交罪修法應該停止，*台灣法學雜誌*，175期，頁3（2011年）。同樣對該次修法表示高度肯定者，如黃惠婷，證明「違反意願」非強制性交罪之必要條件——簡評九九年度台上字第四八九四號判決與九九年刑事庭第七次會議決議，*台灣法學雜誌*，

法，關鍵就在於法律適用者能否對於概括條款提出一個合宜的判準。本文以下將先從「違反意願」的要素定性切入，確認該要素與前導例示概念（強暴、脅迫）之間在解釋上應否存有相互牽制的關聯性，以及在強制性交罪的脈絡下要如何定義「意願」（參、），接著再以此作為基礎，說明個別前導例示概念的應有內涵（肆、），最後則會針對概括條款提出本文的解釋建議（伍、）。但在開始討論現行法的問題之前，有必要先簡單說明當年刪除「至使不能抗拒」要素的修法動機，並釐清舊法的真正問題何在。

貳、舊法「不能抗拒」要素所引發的問題

1999年修法前，刑法第221條第1項的構成要件是「對於婦女以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒而姦淫之者，為強姦罪」。這個條文在當時便飽受批評，被指摘其成罪門檻設在「不能抗拒」對被害人過於嚴苛，「容易造成受侵害者因為需要『拼命抵抗』而造成生命或身體方面更大的傷害」⁶。如果舊法規定果真如反對意見所言，會導致被害人必須竭盡全力反抗才能讓構成要件實現，當然就是荒謬的立法，等於間接表達了被害人應該要冒著死亡或受到嚴重傷害的風險去抵抗行為人⁷。然而，如果我們仔細

161期，頁200（2010年）。從女性主義的觀點進行評釋者，則見陳昭如，基進女性主義的強暴論，思想，23期，頁209以下（2013年）。

6 此為1999年刑法第221條修法理由（三）。類似說法亦見褚劍鴻，刑法分則釋論（上冊），4版，頁650（2004年）；徐偉群（註5），頁3；王曉丹，性暴力法制的歷史交織：一個性別批判的觀點，軍法專刊，60卷2期，頁30（2014年）；林志潔、金孟華，「合理」的懷疑？以女性主義法學觀點檢視性侵害審判之偏見，政大法學評論，127期，頁138（2012年）。

7 此批評已見許玉秀，妨害性自主之強制、乘機與利用權勢——何謂性自主？，台灣本土法學雜誌，42期，頁31（2003年）：刑法不應賦予被害人盡力保護自己的義務，更不應該以被害人未盡力反抗行為人的侵害，來免除對行為人的歸責。

檢視舊法的實體要件，就會出乎意料地發現，即便依照當時的法條文字，技術上也根本沒有如此解釋的空間。詳言之，在被害人的行為能力完全被排除（例如下藥麻醉或是用鐵鍊綑綁），或是被害人曾經反抗卻被行為人制服的情形，要肯定被害人業已不能抗拒當然最不會有爭議。但這些都是「強暴」行為模式才會造成的效果。在強暴之外，立法者還臚列了他種行為模式，特別是「脅迫」這個選項。如果將「不能抗拒」限於物理上無法抵抗，那麼這個要素恐怕就無法透過脅迫來實現。因為只要被害人還有行為能力，即便是被人用槍抵著頭，物理上也還是存有抗拒的可能性，問題只在於成功機率大小以及會遭受何種不利後果。我們當然不能因為物理上存在著這種（幾乎毫無意義的）抗拒可能性，就認定尚未至使不能抗拒。如果不想架空強暴以外的行為模式，當然就必須將心理上癱瘓的情形也列為不能抗拒的類型⁸。事實上，最高法院在舊法時期就已經正確表示：強姦罪所施用之強暴脅迫手段，祇須足以壓抑被害人之抗拒使其喪失意思自由為已足，縱令被害人實際無抗拒行為，仍於強姦罪之成立不生影響（最高法院76年度台上字第7699號刑事判決）。當時的學界也同樣明白主張，在認定被害人是否業已「不能抗拒」時，除了物理上無法抵抗外，也包括被害人心生畏懼或有所顧忌而不敢抵抗的情形⁹。

舊法規定之所以會引發前述成罪門檻過高的批評，其實多半是因為程序上的證明問題。由於強制性交的犯行往往具隱密性，行為地通常是非公開的處所或偏遠無人跡之處，所以法官在確認被害人

8 現行刑法第328條第1項（強盜罪）仍保留了「至使不能抗拒」這個要素，在解釋上當然也應當如此。於此，最高法院也同樣正確指出：只要行為人採用的強制手段足以壓制對方的反抗，縱使被害人並無實際的抗拒行為，亦無礙強盜罪之成立（參見最高法院20年非字第84號刑事判例及最高法院30年上字第3023號刑事判例）。

9 參閱韓忠諫，刑法各論，7版，頁257（1982年）；陳樸生，實用刑法，再版，頁611（1993年）；甘添貴，刑法各論（上），頁365（1990年）；黃東熊，刑法概要，頁335（1998年）。

當初是否同意性行為時，很難找到證人或其他證物，而形成雙方證詞互相對立、證言對抗證言的僵持局面¹⁰。為了避免誤判，法官往往會透過被害人是否有反抗來認定其當下的意向¹¹。如此當然會讓實體法上規定的要件大打折扣，架空強暴以外的行為要素。這固然不是正確的證據評價態度，但問題是出在程序上的證明，而非實體法要件，過去文獻上對於舊法的批判似乎混淆了這兩個層次¹²。儘管如此，立法者還是在1999年的修法中將「不能抗拒」要素刪除，放棄了任何強制程度的要求（包括修法一讀會草案的「至使難以抗拒」），另外增訂了「違反其意願之方法」這個概括條款。如此的修法所直接引發的問題就是，違反意願這個要素和其他行為選項間究竟是處於怎樣的關係？是一種新增的行為模式選項，還是要取代原有「至使不能抗拒」要素，成為所有行為模式在自由妨害程度上的門檻要求？這就是接下來要處理的第一個問題。

¹⁰ 見Ralf Eschelbach, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 2013, § 177 Rn. 12; Osman Isfen, Zur gesetzlichen Normierung des entgegenstehenden Willens bei Sexualdelikten, ZIS 2015, S. 217 (230); 更不用說有時連是否發生過性行為都無法確認，見Tatjana Hörnle, Warum § 177 Abs. 1 StGB durch einen neuen Tatbestand ergänzt werden sollte, ZIS 2015, S. 206 (212).

¹¹ 像是最高法院97年度台上字第4589號刑事判決所指出：「是否違反被害人之意願，自應從客觀之事實，如被害人曾否抵抗、是否試圖逃離、求救、是否曾以言詞或動作表示不同意與之性交而為判斷。否則任何之性交行為，均有可能因一方之事後反悔或其他因素之介入，而成立強制性交罪之危險，自非立法之本意」。本判決的出發點（應謹慎認定事實以避免誤判）固屬正確，但如此的說明文字有可能會讓下級審法官過度偏重被害人有無反抗，而對那些自認抗拒無望的被害人保護不周。

¹² 批評已見黃榮堅（註4），頁1833：「法院的錯誤說法卻被栽贓到法律文字本身」。不過要注意的是，「至使不能抗拒」這個要件嚴格說來也不盡理想，有可能造成法律適用取決於法官恣意認定的後果，詳見下文伍、五、（二）的分析。

參、違反意願要素的體系定位及意義

修法前，舊法第221條第1項「至使不能抗拒」這個要素很清楚地不僅只是要限制概括條款（他法），而是對於所有強制行為選項（強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法）在妨害自由程度上的要求。修法後該要素被刪除，立法者另外又加上「違反其意願」一語，有學者便延續舊法的結構，將「違反意願」要素理解成一個與強制行為、性交行為並列的獨立要素¹³，也就是一種強制程度上的要求。純從法條文字來看，這種解讀方式似乎顯得突兀，因為「違反其意願」這幾個字，從語句結構的觀點來看，應該就只是在描述概括條款（其他方法）的內容；既不是要取代修法前的「不能抗拒」要素，也不是強暴、脅迫的「結果」，而是一種新增的行為選項（行為模式的選擇要素）¹⁴。不過，在立法技術上，例示性描述（*exemplifizierende Umschreibungen*）這種立法模式的功能，就是讓法律適用者能夠更加精準地掌握概括（一般）條款（*Generalklausel*）的內容。換句話說，前導的例示概念不但會讓條文的描述變得更清楚，也為概括條款提供具體的解釋方向¹⁵。立法者透過這種具有截堵功能的一般條款，就已經對於構成要件的適用範圍劃定了最外圍的界線；前導例示概念的添加，並不會對於構成要件的外延產生任何影響，僅具範例的功能¹⁶。基於這樣的理解，強暴、脅

¹³ 如盧映潔，刑法分則新論，10版，頁367以下（2015年）。

¹⁴ 已見黃惠婷（註5），頁200-203。但這在司法實務上倒也不陌生，在解釋毀損罪（刑法第352條與第354條）中「致令不堪用」要素時，儘管法條明明白白地將之與其他行為模式（毀棄與損壞）選言式的並列，實務上還是經常把「致令不堪用」當作是對毀棄與損壞在程度上的要求，主張「毀棄損壞必須達於致令不堪用的程度」，如司法院（74）廳刑一字第452號函。

¹⁵ 參閱Volker Krey, Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, Eine Einführung in die Problematik des Analogieverbots, 1977, S. 224；黃茂榮，法學方法與現代民法，5版，頁280-281（2006年）。除非立法者在描述概括條款時，完全未做任何限制（像是刑法第288條第1項：服藥或以他法墮胎），自然就另當別論。

¹⁶ 國內有文獻因為如此而認為這些例示概念「失去其作為構成要件要素之意義」，如彭國能，刑法分則釋義精解，頁258（2013年）。這樣的看法似嫌速

迫與恐嚇自然也必須具有違反被害人意願的性質。唯有如此解釋，才能合於條文中「其他」一語。舉例來說，當我們講出「桌子、椅子或其他傢俱」這句話的時候，其實蘊含了桌椅也是傢俱的意思。基此，違反被害人意願雖然不是獨立於行為選項的強制程度要求，但仍舊是所有例示概念都必須具備的共通性質¹⁷。倘若得有相對人的有效同意，當然會形成阻卻構成要件該當性的後果。

在本罪的脈絡下，所謂的違反意願，依照本文以下將會另行證立的看法¹⁸，就是指被害人關於是否從事性行為的選擇自由被剝奪。反之，如果被害人的性交決定可被評價為自我選擇的結果，該決定即屬自主做成，沒有違反其意願可言。對於強暴這種行為模式來說，本即含有違背（壓抑）他人意願的性質¹⁹，甚至是提前排除他人意思形成的可能性（如麻醉）。當被害人遭受強暴行為的物理性壓制時，除了忍受對方的行為外，已經沒有其他的行為選項，故

斷，忽略了例示概念限制解釋方向的功能，詳見下文伍、五、的分析。

17 相同見解已見許玉秀，重新學習性自主——勇敢面對問題，月旦法學雜誌，200期，頁311（2012年）；例示最明顯違反意願的態樣；黃惠婷（註5），頁202-203；強暴或脅迫含有壓制他人意思決定與行動自由的意義，理所當然是違反他人意願；黃惠婷，刑法案例研習（三），頁214（2011年）。

18 詳見下文肆、二、（一）。至於學說上對於違反意願要素所提出的各種解釋版本，則請參閱下文伍、的整理與評析。

19 已見盧映潔（註13），頁365；黃惠婷（註5），頁200-203。唯一的例外，就是相對人對性交行為並無反抗的意思，像是雙方對於綑綁拘束及性交均存有同意的情形。此時，物理上的束縛即非用來壓制相對人的反抗，不會該當本罪的強暴概念。除此之外，也包括像是將襁褓中不具行動能力的初生嬰兒抱起或固定的行為。此時行為人雖然也透過身體力量的施展形成了物理強制效用（把嬰兒扭動的身體固定住），但由於嬰兒對於相關的性事務並無理解，自然就稱不上違反其意願。若依本文看法，本罪的例示概念亦須具有違反意願的性質，上開情形自不該當強暴概念。類似說法已見盧映潔，「意不意願」很重要嗎？評高雄地方法院九十九年訴字第四二二號判決暨最高法院九十九年第七次刑庭決議，月旦法學雜誌，186期，頁172（2010年）；違反意願以客體具有意願為前提。但也有不少學者認為此時業已該當強暴，可構成強制性交罪，如高金桂，強制性交罪的強制力行使——高雄地方法院九十九年度訴字第四二二號判決評析，月旦法學雜誌，189期，頁257（2011年）；鄭逸哲，與未滿16歲人進行性接觸之刑法適用，法令月刊，61卷12期，頁37（2010年）；黃惠婷（註5），頁202。

無所謂個體應承擔自己的意志實踐（自主）可言²⁰。至於在脅迫與恐嚇的情形，若是亦應具有違反被害人意願的性質，那麼脅迫或恐嚇的惡害內容就不能包含一切的不利後果，而必須有所限縮。至於要如何限縮，我們將在下文肆、二、（一）進一步地分析。在這裡無論如何可以先行確定的是，如果一個人主動將性行為與其他條件連結，也就是自行提出允諾性行為供他人選擇，而對方接受了性行為選項時，無論要約人經歷了多痛苦的內心掙扎才提出這個用性行為交換其他利益的建議，都不會影響該建議的自主性；除非其嗣後反悔收回允諾，否則該次的性行為就不能評價成違反其意願。像是：

【例1】甲因投資房地產失利，資金全被套牢，無法償還積欠富商乙的100萬元債務。甲知道乙覬覦自己姿色已久，儘管有千萬個不願意，幾經盤算後還是提出「錢債肉償」的建議，打算用性行為來換取債務免除。甲接受建議與乙從事性交，債務一筆勾銷。

在本例中，接受性行為選項的乙不但沒有妨害甲的自由意志，甚至是相反地協助對方實現其自主決定。在一個自由法治國家的法秩序中，受規範者有權根據自我的好惡規則來組織自身所持有的利益，法規範不應介入干涉利益交換的行為。否則將會過度限制受規範者的行為自由（例如剝奪人民利用性行為擺脫經濟困境的機會），同時也是透過刑罰來維護特定的性道德觀（不應用性行為來換取經濟利益），無法在現代法治國刑法學理上取得正當性²¹。接下來，我們就基於上述的理解前提，逐一檢視前導例示概念在解釋上應否以及如何限縮。

20 參閱Thomas Rönau, Willensmängel bei der Einwilligung im Strafrecht, 2001, S. 233.

21 一個行為即便明顯不道德、在倫理上應受非難或是重大違反風俗，也還不足以正當化對該行為施加的刑罰制裁，這已成為現代刑法學界的共識，僅參閱Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band 1, 4. Aufl., 2006, 2/17 ff.

肆、前導例示概念

一、強暴

刑法上的強暴（Gewalt），是指用來排除他人（實際上或預期將會發生）之抵抗所施展的物理（身體）力量，迫使相對人從事（或忍受）特定行為²²，是一種物理上的強制（*physischer Zwang*），接近（但不等同）日常用語中的暴力²³。最典型的情形，是直接對相對人的身體施加作用（像是將被害人壓倒在地，或是加以綑綁），這就是所謂的「對人強暴」（*Gewalt gegen Person*）。不過強暴並不限於直接對人施加，亦可透過對物的作用，進而使得相對人無法驅動特定意志²⁴，也就是所謂的「對物強暴」（*Gewalt gegen Sachen*）²⁵。在強制罪（刑法第304條）的脈絡下，強暴概念兼含對人強暴與對物強暴二者；因為即便只是對物施行，也會影響到他人意志的貫徹、妨礙他人的自由（例如身障者無法使用被摧毀的輪椅離開，或是黑夜中無法使用被切斷電源的空間）²⁶。但在強制性交罪的適用上，如果不設任何限制，同樣也將對物施行的暴力（像是

22 見Ernst Träger/Gerhard Altwater, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 12. Aufl., 2001, § 240 Rn. 7。德國帝國法院將強暴定義為：（1）行為人施展身體力量，（2）對於他人的身體產生直接效果，（3）行為人主觀上的目的在於透過身體力量壓制對方（事實上或可預期的）抵抗。這就是所謂古典的強暴概念，隨後德國實務界對之進行了一連串「精神化」（*Vergeistigung*）的改造，亦即放寬前述（1）和（2）的要求，讓單純的靜坐也被評價成一種強暴，引發違反罪刑法定原則的批評。對此，可參閱Klaus Geppert, Die Nötigung (§ 240 StGB), Jura 2006, S. 31 (33 ff.)，國內文獻則可參閱王皇玉，強制罪之比較研究，軍法專刊，59卷5期，頁2以下（2013年）的介紹。由於這段概念演變過程對於性犯罪沒有直接影響，故本文不予處理。

23 有文獻將這兩個概念等同看待，如高金桂（註19），頁256，應該是對於「暴力」概念的理解有所不同。

24 參閱Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 8.

25 亦有認「對物強暴」一詞有誤導之嫌，因為強制效果並非出現在物件本身，而是發生在被強制的人身上，所以仍屬對人的強暴，只不過是透過對物件的作用間接形成對人的強暴，如Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 49.

26 參閱Geppert (Fn. 22), S. 35.

在出口處設置障礙物阻止被害人離開，或是將車輛緊貼牆壁停靠，讓坐在副駕駛座的被害人無法開門下車）納入，其實並無實益。因為本罪的構成要件行為還包括了性交，而性交又限於行為人與被害人的身體有所接觸²⁷。對物施暴只是達到妨害一般自由的程度，如果相對人不願從事性交，行為人勢必還要再另外施行壓制對方意願的手段（透過身體力量壓制對方反抗的對人強暴，或是另行施加脅迫、恐嚇），才有接觸到被害人的可能。有鑑於此，德國實務界便主張，此處應排除單純對物施行的強暴，這樣的看法也在德國文獻上獲得不少支持²⁸。更何況在定式犯罪的類型，多數學者認為，當行為人從事了構成要件所描述的行為模式就必然進入該罪的未遂階段²⁹。如果將對物強暴一概理解成本罪的構成要件該當行為，而不考慮其與後續性交行為間的密接程度，勢必會不當提前著手的時

27 參見刑法第10條第5項的立法定義。在德國法上亦同，僅參閱Joachim Renzikowski, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2005, § 177 Rn. 52; Laubenthal (Fn. 2), Rn. 156 ff., 218。若是沒有任何身體接觸，像是逼迫對方裸體，則是透過強制罪來掌握（Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte, 5. Aufl., 2002, 66/11.）。

28 僅參閱Thomas Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 62. Aufl., 2015, § 177 Rn. 9; Karl Lackner/Kristian Kühl, Strafgesetzbuch, 27. Aufl., 2011, § 177 Rn. 4; Monika Frommel, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch, 3. Aufl., 2013, § 177 Rn. 40; Eschelbach (Fn. 10), § 177 Rn. 16。但也有學者主張，此處的解釋應與強制罪一致，也包含對物的強暴，如Renzikowski (Fn. 27), § 177 Rn. 41; Tatjana Hörnle, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 12. Aufl., 2010, § 177 Rn. 33, 53; Karl Heinz Gössel, Das neue Sexualstrafrecht, 2005, 2/21。國內學界對此問題亦有不同看法，有認應限於對人強暴者，如蔡墩銘，刑法各論，5版，頁397（2006年）：須對於人之身體為之；主張應包括對物強暴者，則如黃惠婷（註17），頁216。

29 僅參閱Uwe Murmann, Grundkurs Strafrecht, 2. Aufl., 2013, 28/64; Jürgen Baumann/Ulrich Weber/Wolfgang Mitsch, Strafrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl., 2003, 26/50，這就是所謂的「部分實現規則」（Teilverwirklichungsregel）。我國最高法院向來亦主張，當行為人「開始實行構成犯罪要件之行為」時即屬著手，參見最高法院30年上字第684號刑事判例、最高法院84年度台上字第904號、84年度台上字第5900號、86年度台上字第3001號、88年度台上字第531號、91年度台上字第1542號以及95年度台上字第4608號等刑事判決。

點，過度擴張本罪未遂犯的成立範圍。不過必須留意的是，對物強暴有時候也會同時體現為一種脅迫行為（像是行為人用刀割開被害人衣物的行為，往往也含有遇到抵抗時會用武力傷害的意思），還是有構成本罪的可能³⁰。不過這就已經是另一個問題（默示脅迫的認定），與本文此處的主張不相衝突。

其次，依照德國學界看法，強暴概念又可再區分出絕對強暴（vis absoluta）與逼迫式強暴（vis compulsiva）兩種次類型。前者又稱為無法抗拒的強暴（unwiderstehliche Gewalt）³¹，作用方式是壓制意願（willensbrechend），直接在物理上剝奪相對人的行為可能性³²，讓對方無法形成意志（例如被麻醉）³³或無法驅動其意志（例如被綑綁固定）³⁴。後者的作用方式則是扭曲意願（willensbeugend），亦即透過物理力量的施展將他人的意志驅動逼往特定方向，迫使其做出一定的行為選擇。這種強暴形式，可以直接對他人的身體施展（例如透過踢踹使受攻擊者前往行為人所希望的位置），也可以只是間接地作用（例如開車衝向他人迫使對方跳

30 參見 Walter Perron/Jörg Eisele, in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., 2014, § 177 Rn. 5a。由於本文對於脅迫的行為態樣另外提出了「惡害之現時性」（Gegenwärtigkeit des Übels）要求（詳見下文肆、二、（一）），能夠同時被評價成脅迫的對物強暴行為，在時間上必然和後續的性交行為緊密連結，才會被解讀成現時的生命、身體威脅。如果只是單純的鎖上門，或是將車輛緊靠障礙物停放，原則上還不會被評價成默示的脅迫，所以不會有著手時點過於提前的問題。

31 語見 Geppert (Fn. 22), S. 33.

32 見 Knut Amelung, Über Freiheit und Freiwilligkeit auf der Opferseite der Strafnorm, GA 1999, S. 182 (195).

33 由於古典強暴概念相當強調行為人身體力量的施展（die Entfaltung körperlicher Kraft），所以暗中使用藥劑迷昏相對人的行為便不會該當強暴（此見 Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 11的整理），這或許就是舊法強姦罪將藥劑與強暴並列的原因。但有鑑於使用藥劑迷昏他人和透過暴力將之擊昏在物理上對於意思形成的影響相當，德國聯邦最高法院後來便不再執著於行為人身體力量耗費的程度要求，而將藥劑麻醉也納入強暴概念，參閱 Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 13.

34 參閱 Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 7.

開，或是突然切入旁邊車道，逼使後方車輛煞車或變換車道)³⁵。逼迫式強暴雖然亦可壓制相對人的意思決定自由（所以也是強制罪的適格行為模式），但在強制性交罪的脈絡下，除非行為人是要藉此來傳達將來的惡害（像是持刀揮向對方，除了逼使對方跳開閃躲外，有時也會含有若不順從將會再度攻擊的意思），因此可透過默示脅迫成立本罪，否則單靠逼迫式的強暴行為本身，無法直接促成相對人接受性交行為，所以仍無法該當本罪的強暴行為選項³⁶。

最後還要附帶說明「催眠術」這個例示選擇要素。立法者在強暴類型之外，又將催眠術單獨列出，然而，催眠術可以直接排除相對人意思形成的可能，應該和使用麻醉方法做相同的理解，原本即屬前述絕對強暴的一種態樣³⁷。當初立法者將這些概念與強暴並列，很可能是因為採行了早期較狹隘的古典強暴概念³⁸。但既然現今的強暴概念業已擴及排除意思形成能力的類型，那麼在強暴之外將藥劑與催眠術單獨列出即屬多餘，僅具提示作用而已。

二、脅迫

（一）惡害內容的限縮？

脅迫（Drohung），是指行為人對受脅迫者預示某種惡害，若不順從其要求，將會促使（或任由）該惡害實現³⁹。這種惡害的預告，除了明示外，亦可透過默示的方式來傳達，讓相對人透過行為

³⁵ Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 7.

³⁶ 德國通說則認為，性強制罪的強暴亦包含逼迫式強暴，僅參閱Frommel (Fn. 28), § 177 Rn. 40.

³⁷ 現今德國通說見解，僅參閱Reinhard Maurach/Friedrich-Christian Schroeder/Manfred Maiwald, Strafrecht, Besonderer Teil, Teilband 1, 9. Aufl., 2003, 13/13, 18/10; Perron/Eisele (Fn. 30), § 177 Rn. 5。國內亦已有文獻指出此點，如黃惠婷，刑法上的強盜罪，頁6（2005年）：藥劑與催眠術均屬強暴手段的特別例示。

³⁸ 早年因為將催眠看作是純粹心理方面的影響，所以認其不合於物理強制的強暴概念，此見Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 11, 13的整理。

³⁹ Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 56.

人的肢體動作得以推斷出自己內心的意思⁴⁰。行為人當然也可以透過強暴行為來實現默示的脅迫，亦即，透過先前施行的強暴行為，表達出「若不順從將會繼續施暴」的意思⁴¹。刑法第221條第1項並沒有對於脅迫的惡害內容做任何限制，形式上看來，似乎可以比照強制罪的解釋，包含各種內容的惡害⁴²。然而，如果惡害的內容僅止於名譽、自由甚或財產上的不利益，被害人經過利害權衡後做出接（忍）受性行為的決定，是否仍屬違反意願，便有進一步探究的必要，像是以下的情形：

【例2】旅店業者甲透過針孔攝影機偷拍乙女和第三人性交的影片，持以威脅乙若不與之發生性關係，將在網路上公開影片。乙幾番考量後，選擇屈從甲的要求⁴³。

在舊法時期，因為條文中另外還有「至使不能抗拒」這個要素，所以即便不對脅迫內容附加任何限制，在行為人僅以財產或名譽上之不利益相脅的情形，法律適用者無論如何都還能夠另以「未至使相對人無法抗拒」為由，否定強姦罪的成立⁴⁴。但在立法者將「至使不能抗拒」要素刪除後，便迫使我們必須認真面對這個老問題。與此相對，德國刑法第177條第1項的性強制罪（sexuelle

40 Gereon Wolters/Eckhard Horn, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 8. Aufl., 2013, § 177 Rn. 9.

41 見Johannes Wessels/Michael Hettinger, Strafrecht, Besonderer Teil 1, 34. Aufl., 2010, Rn. 403; Hörnle (Fn. 28), § 177 Rn. 87.

42 所謂的惡害（Übel），就是會讓人感受到痛苦、不愉快的不利後果，當然必須達到需要刑法介入的程度，這就是德國刑法中明文要求的惡害之「可感受性」（Empfindlichkeit）。依此，朋友間單純的絕交預告，原則上就還不能算是刑法上的脅迫（Geppert (Fn. 22), S. 36; Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 57.）。

43 另一個值得討論的案件，則是臺灣高等法院100年度侵上訴字第252號刑事判決。該案被告以殺害犬隻來逼迫飼主與之發生性關係，法院肯定恐嚇殺狗亦該當本罪的脅迫要素，但由於該案中被告另有實施對人身的暴力攻擊（強暴），所以判決中並沒有對於脅迫的部分多做說明。

44 但若是沒有進一步說清楚「至使不能抗拒」要素的認定判準，那麼即便在舊法時期，這類的案例恐怕也還是會引發爭議。關於「至使不能抗拒」的認定問題，詳見下文伍、五、（二）的分析。

Nötigung)⁴⁵所規定的強制手段中，脅迫則是限於以「生命或身體之現時危險」(mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben)作為惡害內容。如果行為人是用生命或身體的現時危險來脅迫（例如持刀逼使對方就範），即使被害人經過考慮後決定放棄抵抗而忍受性行為，也不能因此認為並未違反其意願，因其同意只是強制逼迫的效果。但若行為人是使用其他的不利後果作為脅迫內容，像是經濟或名譽上的不利益（如開除、解約或是揭發醜聞），或者是以對自己施加惡害（如自殺）相脅，則不包括在內⁴⁶。

德國的立法者之所以在性強制罪的脈絡加上如此的限制，箇中的道理其實不難懂。如果行為人是以身體的現時危險作為惡害內容，那麼與「忍受性行為」並列的選項，就不會是單純地「忍受惡害實現」，而是在接受惡害實現（被毆打制服）之餘，還是可能必須要接受性行為。換句話說，行為人透過這類脅迫所表達的意思是

45 在1998年修法前，該條名稱原為強姦（Vergewaltigung），其中第1項規定：以強暴或對生命或身體現時危險之脅迫，強制婦女與自己或第三人為婚姻關係以外之性交（Beischlaf）者，處2年以上之自由刑。當時條文中所稱的「性交」一詞，與我國舊法時期的「姦淫」理解相同，係指異性間性器官的接合行為。而該國舊刑法第178條的性強制罪，則是類似我國的強制猥褻罪。1998年修法後，這兩個條文被合併成現今的性強制罪（第177條），第1項為基本構成要件（法定刑為1年以上自由刑），其中所使用的「性的行為」（sexuelle Handlungen）一詞，泛指客觀上具有性關聯（Sexualbezogenheit）的行為（僅參閱Laubenthal (Fn. 2), Rn. 102.），概念上包含了我國法所稱的性交與猥褻，第2項則是針對侵入身體的性行為（性交）設有加重刑罰的規定（原則性的量刑例示規則，刑度為2年以上自由刑）。

46 Fischer (Fn. 28), § 177 Rn. 18b; Wolters/Horn (Fn. 40), § 177 Rn. 12. 至於在行為人以剝奪行動自由相脅的情形，除非自由剝奪的時間持續長度可能會引發健康損害，否則亦不該當該國的性強制罪；見Hörnle (Fn. 28), § 177 Rn. 72。不過要特別注意的是，用生命或身體以外的其他惡害作為脅迫內容，雖然依照德國法不會構成性強制罪，但仍有構成強制罪的可能，而且是成立加重強制罪。德國的立法者於1998年特別在該國刑法第240條（強制罪）第4項（原則性例示加重事由）增訂了第1款「強制他人為性行為」，作為普通強制罪與性強制罪二者間的過渡條款，參見Gunther Arzt/Ulrich Weber/Bernd Heinrich/Eric Hilgendorf, Strafrecht, Besonderer Teil, 2009, 10/15; Albin Eser/Jörg Eisele, in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., 2014, § 240 Rn. 38.

「別敬酒不吃，吃罰酒」，被害人其實只有「不被攻擊地接受性行為」與「被攻擊而接受性行為」這兩個選項，對於要不要接受性行為這一點完全沒有選擇的餘地，並無選擇自由（Auswahl-Freiheit）意義下的主觀自由可言⁴⁷。隨而，當其放棄抵抗並忍受性行為時，自然就不能解讀成被害人有做出從事性行為的選擇。由於被害人的行為並非出於自主，行為人所從事的性交行為自然就是違反其意願。如果行為人是以殺害對方作為惡害內容，那麼與接受性行為並列的選項則是「死亡」（失去一切利益）及「被攻擊後接受性行為」，當然就更加排除了全身而退的可能性⁴⁸。與此相對，行為人如果是以生命或身體以外的其他利益相脅，像是用名譽或財產上的不利後果作為惡害內容，那麼被害人對於是否接受性行為這一點就還是有選擇的空間；儘管心理上受到壓迫，但終究還是在「不為性交＋忍受惡害實現」與「為性交＋惡害不實現」這兩個選項中做出決定。若是自主做出放棄或交換法益的決定，便無違反其意願可言⁴⁹。這就好像在滂沱大雨中，為了趕車而跑出騎樓冒雨奔向車站，就是在耗費時間（等雨停、錯過特定班次火車）和衣物浸濕這兩個不利後果中選擇，無論如何決定，都是合於意願。儘管心中不希望衣物被淋濕，但這只是冒雨趕車這個行為選擇的負面效應所引

⁴⁷ 概念用語參考自Ernst-Wolfgang Böckenförde, *Recht, Staat, Freiheit*, 1991, S. 44.

⁴⁸ 相同的道理，在德國學界則是應用在強盜罪的討論。面對搶匪「要錢還是要命」的問法，被害人的選項是「金錢損失」和「金錢損失＋喪失生命」，對於財物持有的失去來說，並無選擇自由，因此並沒有阻卻構成要件的同意可言，此見Erich Samson, *Strafrecht II*, 5. Aufl., 1985, S. 109; Erich Samson, *Grundprobleme des Betrugstatbestandes* (2. Teil), JA 1978, S. 564 (566).

⁴⁹ 此處乃參考Rönnau (Fn. 20), S. 454對於承諾意思瑕疵問題的分析。要注意的是，這類的脅迫仍有可能構成強制罪。而在強制罪的判斷上，關鍵就不在被害人是否仍有自主選擇的空間，而是被害人在法律上是否應該面對這種抉擇情境。舉例來說，行為人以砸毀被害人的車子來逼迫被害人與之性交，被害人經過衡量後應允，依照本文的看法，行為人是透過財產上的不利益相脅，故被害人仍屬自主做成性交的決定，不構成強制性交罪。但被害人原本無需面對這樣的選擇，行為人惡化了被害人在法律上受擔保的自由地位，所以仍成立強制罪。

發的片面情緒，並不會影響到這個決定的自主性（選擇自由）。

這樣的解釋，很大程度上悖離了國內多數文獻在修法後對本罪的理解。像是在【例2】這種以公開裸照或其他性愛資料相脅的情形，不少學者認為應成立本罪⁵⁰，甚至由此反向批評德國立法限縮脅迫內容的不妥⁵¹。可以肯定的是，任何以惡害相脅的行為或多或少都會影響到相對人的意思決定自由。然而，現行強制性交罪的構成要件中既然明白列出了「違反意願」要素，而前導例示概念又必須具備違反意願的性質（前文參、），那麼關鍵提問就應該是：被害人在衡量利弊後做成了接受性交的決定，是否仍屬違反其意願？依照前面提出的看法，只要被害人仍有選擇空間，做出來的決定就是出於自主意願，對方就不會該當本罪⁵²。至於意思形成過程中遭到外力扭曲這個不法事實，在一定前提下則可透過（未以違反意願作為構成要件要素的）強制罪來掌握。倘若覺得強制罪的處罰過輕，無法充分評價逼使他人接受性行為的不法內涵，那麼在立法政策上，至少有以下幾種修法模式可供選擇。首先，立法者可以在妨害自由罪章中，另行針對性行為的妨害自由類型，增設加重的強制構成要件⁵³，作為強制罪與本罪間的過渡類型。其次，立法者也可以選擇刪除本罪概括條款中的「違反意願」要素，改採強制罪的構

⁵⁰ 如柯耀程，情人看招（糟）！，月旦法學教室，66期，頁19（2008年）；徐偉群（註5），頁3。

⁵¹ 如徐偉群（註5），頁3。

⁵² 綜觀目前學說上對於違反意願要素所提出的各種判準（見下文伍、一、的彙整），恐怕也只有「非心甘情願」的解釋立場在這裡才會必然得出肯定的結論。但這個寬鬆的判準會讓本罪的適用範圍不當膨脹（對此詳見下文伍、二、的分析）。至於此時是否仍屬未經同意、是否該當「低度強制手段」或「足使不能抗拒」，則是取決於各個判準的細部解讀，這也正是必然會引發爭議的所在。

⁵³ 亦即仿效德國刑法第240條（強制罪）第4項第1款的立法（條文見前註46），另行增定強制罪的加重構成要件（如：強制他人為性交或猥褻行為者，處5年以下有期徒刑）。此種修法建議已見許澤天，面臨合法惡害威脅下的性自主，台灣法學雜誌，181期，頁125（2011年）。

成要件結構，僅將結果從「使人行無義務之事」改成「使人實施性交或接受他人對之性交」，便可對於本罪的脅迫要素做出與強制罪相同的解釋⁵⁴。立法者甚至也可以考慮放棄複（雙）行為犯的構成要件結構，將本罪的構成要件行為僅限定在特定前提下的性交行為⁵⁵。無論採取何種修法模式，立法者都必須審慎避免過度限制當事人（包括被害人）的行為自由。若是將一切附加不利後果的性行為要約都納入本罪的處罰範圍，就等於是在刑法上提出一種交換禁令（Tauschverbot），全面限制了每個人透過性接觸來自行擺脫困境的可能性（Selbstbefreiungsmöglichkeiten）⁵⁶，剝奪了受規範者根據自身的價值觀與好惡規則來組織自己利益的空間。就以前文所舉的【例1】來說，如果錢債肉償的建議是債權人所提出，只因為相對人是在惡害（還債）的逼迫下痛苦地接受性交選項，便將整個行為評價成違反其意願，除了嚴重偏離於一般人對於本罪所理解的固有圖像外⁵⁷，也同時是在規範上阻絕了被害人進入此種抉擇情境（身體vs.金錢）的可能性，剝奪相對人利用性行為脫離經濟困境的機會。事實上，這裡所涉及者只是個人的價值選擇，無論在道德層面要如何評價，法律都不應當介入⁵⁸。即便性接觸的動機並非單純的愛慕

54 如此修改後，本罪就直接成為加重的強制類型。採取此種修法模式必須一併思考的是，用經濟上的不利益作為脅迫內容時，現行法的刑度是否過重。

55 依照德國學者Hörnle的考證，強制性交罪的雙行為犯結構已有百年以上的歷史，而最初的立法設計顯然不會是立於保護性自主決定權的基礎上。因此，在性自主決定權的觀察視角下，這樣的構成要件設計自屬過時（參閱Tatjana Hörnle, Wie § 177 StGB ergänzt werden sollte, GA 2015, S. 313 (314).）。而在單行為犯的結構下，又有強調被害人的反對意思（拒絕）以及強調被害人的允許（同意）這兩種不同方向的立法模式，各會形成不同內容的行為規範，詳見下文伍、三、的分析。

56 此概念參考自Amelung (Fn. 32), S. 201 f.（但本文多處結論與該文相異）。

57 結論相同者，已見林山田，刑法各罪論（上），5版，頁226（2005年），其在概括條款的脈絡下討論；許澤天（註53），頁124。

58 事實上，債權人在這裡不但沒有惡化債務人的法律地位，反而還提供了更多的行為選擇，因此，是否構成強制罪仍有討論空間。學說上於此有不同意見，可參閱吳耀宗，犯罪與法之抗制（一），頁133以下（2000年）的學說整理與分析。但如果行為人提出的不利後果並非被害人原本即應面對的處境，而是因為

或肉體上的渴望，而是為了穩定或改善自己的社經處境，或者是為了換取免於被舉發犯罪的優惠，其性接觸的決定也還是自主做成，稱不上違反意願，法律無權過問⁵⁹。

最後，強制性交罪作為一種加重的特殊強制型態，法定刑之所以可以從原本強制罪所規定的「3年以下有期徒刑」躍升到「3年以上10年以下有期徒刑」，除了是因為行為人主觀上特別值得非難的強制目的（性交行為）外，在強制程度上也應該要和一般的強制罪有所不同，否則將難以正當化法定刑的大幅跳躍。舊法強姦罪透過「不能抗拒」這個要素，就是要將該罪的適用限縮在存有最高強制程度的情形。現行法中雖然不再有限制強制程度的要素，法律適用者還是可以從強制手段的內容上進行限縮。

「恐嚇」本質上也是一種將來惡害的告知，是否與脅迫相異，學說及實務上有不同的看法。早期學說與實務曾經主張二者在惡害的急迫性方面有所差異：脅迫是以「現時」的惡害為內容，恐嚇則是以「將來」的惡害為內容⁶⁰。易言之，脅迫的被害人所面臨的是一種必須立即抉擇（甚或根本沒有選擇機會）的情境，與此相對，恐嚇的被害人則還有一定的選擇空間，可以在利益衡量後做出抉擇⁶¹。然而，脅迫與恐嚇在本質上並無不同，都是將被害人推入一

行為人的非法脅迫而生（例如，地痞流氓強迫攤販繳交保護費，並提出可以用性行為來抵償保護費的建議），被害人原本既然沒有接受該惡害實現的義務，行為人的脅迫便惡化了被害人的法律地位，減縮了對方受法律擔保的自由空間，應成立強制罪。

59 此見Hörnle (Fn. 55), S. 323.

60 如褚劍鴻，刑事法學論著，頁356以下（1991年）；甘添貴（註3），頁236；許玉秀，刑法的問題與對策，頁281-282（1999年）（以下簡稱：許玉秀，刑法對策）；許玉秀（註7），頁30。另最高法院49年台上字第266號刑事判例亦同，甚至近年來仍可在少數判決中見到此種主張，如最高法院100年度台上字第6090號刑事判決：是恐嚇行為，係指以將來惡害之通知、恫嚇他人而言，受恐嚇之被害人尚有自由意志，祇不過因此而懷有恐懼之心，要與強盜行為係以目前之危害脅迫他人，致喪失自由意志不能抗拒者，有所不同。

61 許玉秀，刑法對策（註60），頁281-282。

種必須在壓迫下做出抉擇的情境，而行為人所預示的惡害（不利後果），始終都是未來的惡害，差別只在於急迫的程度（下一秒或下個月），強要區分現時惡害與將來惡害二者，只是徒增技術上的困擾，並且會在那些僅以脅迫作為行為模式而未列出恐嚇的犯罪類型（如準強盜罪）形成不必要的處罰漏洞⁶²。最高法院80年度第4次刑事庭會議決議亦傾向二者本質相同的立場⁶³。若依此種看法，則現行法條文中將二者並列的作法即屬多餘⁶⁴。

（二）超自然的惡害？

依照學說上的一致看法，脅迫性的意思表示亦可透過詐術來傳達。由於脅迫本來就不要求行為人確實有實現惡害的真意及能力，只要該惡害的表示能夠在客觀上喚起應認真對待的印象，會讓訊息接收者認為行為人有可能促使該惡害實現，即為已足⁶⁵。依此，行為人若是透過詐術來傳達脅迫性的意思表示，而其所主張的惡害內容也是人力所能支配（像是謊稱手中的玩具手槍為真槍），想藉此讓被害人信以為真而屈從，那麼詐術便已成為脅迫的成分，還是可

62 不過這個漏洞並不會出現在強制性交罪，因為刑法第221條第1項將這兩種行為模式並列。

63 決議文指出：「恐嚇行為不以將來之惡害通知為限，即以強暴脅迫為手段，而被害人未達於不能抗拒程度者，亦屬之」。另，陳子平，強盜罪與恐嚇取財罪之界限，月旦裁判時報，31期，頁38（2015年）亦同此旨。要注意的是，恐嚇行為的定性與相對人是否業已不能抗拒應該是兩件事，上開決議似乎將之混為一談。

64 此批評已見褚劍鴻（註6），頁649；陳子平，刑法各論（上），頁206（2013年）；吳耀宗，強制性交罪與利用權勢性交罪，月旦法學教室，63期，頁17（2008年）；薛智仁，強制性交罪（刑法第二二一條第一項）修正之研究，刑事法雜誌，44卷1期，頁93-94（2000年）。另亦有從其他角度批評加入恐嚇選項者，如甘添貴（註3），頁236；許玉秀（註7），頁30；甚至有學者直指恐嚇並非強制，如陳志龍，酒不罪人，人自罪——妨害性自主罪之探論，月旦法學雜誌，75期，頁13（2001年）。

65 僅參閱 *Urs Kindhäuser*, *Strafrecht, Besonderer Teil 1*, 5. Aufl., 2012, 12/32; *Wessels/Hettinger* (Fn. 41), Rn. 404.

該當脅迫要素⁶⁶。這種情形，就和行為人手持真槍但不打算使用一樣，關鍵只在於能否促使相對人認真看待威脅。會引發爭論的情形，是行為人以人力無法支配的超自然力量作為惡害內容，宣稱自己能夠支配運用超自然的神怪力量，藉此讓篤信該宣稱的被害人做出與自己性交的決定，也就是一般俗稱的「宗教騙色」案件，像是：

【例3】甲對信徒乙宣稱自己為聖靈，看到對方及其父母將會遭受意外死亡，但只要與之發生性關係，便可拯救家人，若不相信，父母便會死亡下地獄等語，並敘述關於地獄恐怖情事，致使乙信以為真並心生恐懼，任由甲對之實施性交行為⁶⁷。

這類案件在我國司法實務上並不罕見，我國實務界早在1999年修法前便已肯定這種行為構成強姦罪⁶⁸，修法後最高法院也維持了

66 參閱Hans-Ludwig Günther, Zur Kombination von Täuschung und Drohung bei Betrug und Erpressung, ZStW 88 (1976), S. 960 (961 f.)。(該文雖然是在恐嚇勒索罪的脈絡下討論，不過問題點相同。)我國最高法院亦同此看法，參見最高法院27年滬上字第15號刑事判例：「上訴人奪取財物時，用手放入衣袋，裝作手槍，顯已達於以強暴、脅迫至使被害人不能抗拒之程度，自係刑法第三百二十八條第一項之強盜罪，而非第三百二十五條第一項之搶奪罪」。但國內則有文獻認為，以假槍充作真槍應屬刑法第328條所稱之「他法」，如甘添貴，刑法各論（上），3版，頁257（2013年）。若採此種看法，在準強盜罪就會產生無謂的處罰漏洞，因為該罪的構成要件行為只列出了強暴與脅迫二者，而無概括條款（他法）。詳參閱蔡聖偉，刑法問題研究（二），頁465-466（2013年）。此外，還要注意的是，被害人並不需要確信惡害會成真，即便有所懷疑，亦可該當脅迫；因為只要被害人認為惡害有實現的可能，便會影響其意思決定自由（Träger/Altvater (Fn. 22), § 240 Rn. 56.）。

67 改編最高法院103年度台上字第626號刑事判決的案件事實，該案被告最後被依強制性交罪判處有罪確定。

68 最高法院實例參照：（1）最高法院28年滬上字第25號刑事判例：被告向某女實行姦淫之前，向稱菩薩已來，渾身都要看過，勿得聲張，致其有所畏懼，聽任指揮，即係以他法至使不能抗拒，與乘其不能抗拒而為姦淫之情形不同；（2）最高法院52年度台上字第1024號刑事判決：自稱為齊天大聖乩童，佯言亡魂纏身，並稱適遇亡魂，已代為買回生命，惟須讓其姦淫，否則來日無多，使被害人因聽其言而心生畏懼，致使不能抗拒而被姦淫；（3）最高法院56年度台上字第2210號刑事判決：神棍藉口改運，欺騙自幼生長農村未受教育，智識極端淺

如此的立場，不過更進一步明確指出是透過概括條款（違反意願之他法）來掌握此種行為態樣⁶⁹。這樣的主張也和該院在恐嚇取財罪與詐欺罪所採取的立場一致，亦即否定該當脅迫或恐嚇，但評價為施行詐術⁷⁰。在國內文獻中，多數贊同實務作法，肯定強制性交罪的成立⁷¹。與此相反，德國學界的多數學者則認為，以超自然的力量作為惡害內容並不會該當脅迫概念⁷²，因為脅迫與恐嚇的惡害內

薄之村姑，致使其陷於恐怖，心懷畏懼，聽任姦淫。

69 如最高法院94年度台上字第4598號、99年度台上字第8139號、101年度台上字第1087號、101年度台上字第3973號、102年度台上字第2200號、102年度台上字第3692號與103年度台上字第720號等刑事判決。其中以最高法院102年度台上字第3692號刑事判決的論述最詳細：「刑法第二百二十一條第一項規定所稱『其他違反其意願之方法』，並不以類似同條項所列舉之強暴、脅迫、恐嚇或催眠術等方法為必要，祇要行為人主觀上具備侵害被害人自主之行使、維護，以足使被害人自主決定意願受妨害之任何手段，均屬之。而人之智能本有差異，於遭逢感情、健康、事業等挫折，而處於徬徨無助之際，其意思決定之自主能力顯屬薄弱而易受影響，若又以科學上無法即為印證之手段為誘使（例如法力、神怪、宗教或迷信等），由該行為之外觀，依通常智識能力判斷其方法、目的，欠缺社會相當性，且係趁人急迫無助之心理狀態，以能解除其困境而壓制人之理性思考空間，使之作成通常一般人所不為而損己之性交決定，此行為即屬一種違反意願之方法。是以行為人若施以上開方法而使人為性交之行為，即與犯罪構成要件該當」。

70 實例參見：（1）大理院4年上字第876號刑事判例：遇人患疾延其診治，謊稱見一婢鬼，要索其家五命，須交銀三十兩為之驅逐等情，其人被嚇，遂付銀三十兩，求其禳解者，成立詐欺取財罪；（2）最高法院41年台上字第143號刑事判例：刑法第346條恐嚇罪之構成，須以行為人對於被害人所用之手段，有使其發生畏懼心者為要件。被害人惑於被告所云，見其宅有三種不同色彩靈魂，斷定其家最近死了2人，可能再有一人死去之謊言，信以為真交付財物，求其禳解，是被害人之交付財物，乃不過僅基於被告之欺罔行為，陷於錯誤所致，自與恐嚇罪之要件不合。

71 如甘添貴（註3），頁237；林東茂，刑法綜覽，8版，頁2-68至2-69（2015年）；王皇玉，強制手段與被害人受欺瞞的同意：以強制性交猥褻罪為中心，臺大法學論叢，42卷2期，頁421以下（2013年）；許澤天（註53），頁124；林大為，論詐術性交罪——兼論「宗教騙色」案件之認事用法問題，軍法專刊，59卷5期，頁117以下（2013年）。反對者則如李聖傑，刑法第二二二條第一項第一款「二人以上共同犯之」之適用思考，政大法學評論，115期，頁12註10（2010年）；涂春金、劉柏江，以宗教之名行騙性交是否構成強制性交罪？——兼論臺灣高等法院臺南分院99年度重上更（二）字第78號刑事判決暨最高法院99年度臺上字第8139號刑事判決，軍法專刊，58卷3期，頁55、58以下（2012年）。

72 如Karl Heinz Gössel/Dieter Dölling, Strafrecht, Besonderer Teil 1, 2. Aufl., 2004,

容限於人力所能支配；如果並非行為人所能支配的惡害，即屬不構成犯罪的單純警告（die bloße Warnung）⁷³，而非脅迫或恐嚇。

首先可以確定的是，如果把這種利用宗教信仰的行為悉數歸入「詐術」概念下，會立即面臨難解的技術問題，因為依照目前的科技知識，法院無法驗證這些超自然力量的真偽，如何能斷言行為人的宣稱係屬與客觀實際不相符的事實主張（詐術）？這個問題，在詐欺罪的脈絡下也引發了不小的爭議⁷⁴。如果這種無法驗證真偽的主張也會被定性成詐術，那麼一般的宗教募款、廟宇收費幫人點平安燈、安太歲的行為，就也一併會被評價成施行詐術。而在另一方面，單純的警告之所以不構成脅迫或恐嚇，是因為接收訊息的相對人也知道警告者無法影響、支配惡害是否實現。但在司法實務上，經常見到行為人先透過可被驗證真偽的技術行為（如魔術或科技的手法）讓被害人誤信自己確實具有神力，可透過超自然的力量主宰操控他人的生死，再以此逼迫相對人與之從事性交行為。對於一個深信不疑的相對人來說，這種手段在其主觀上所造成的影響，其實跟騙稱手中握有手槍沒有太大的差別。因此，我們不能單純因為行為人宣稱的惡害涉及到神怪等超自然力量，就全然肯定或否定本罪的成立，而應該要進一步檢視：（1）行為人是否製造了自己可主宰

17/67; Eser/Eisele (Fn. 46), § 240 Rn. 9; Urs Kindhäuser, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar (LPK-StGB), 5. Aufl., 2013, Vor §§ 232-241a Rn. 27; Volker Krey/Uwe Hellmann/Manfred Heinrich, Strafrecht, Besonderer Teil, Band 1, 15. Aufl., 2012, Rn. 375。但亦有學者肯定利用迷信手段可該當脅迫，如 Träger/Altwater (Fn. 22), § 240 Rn. 57; Johannes Wessels/Thomas Hillenkamp, Strafrecht, Besonderer Teil 2, 33. Aufl., 2010, Rn. 707。

⁷³ 所謂的單純警告，是指訊息接收者從行為人告知的內容即可得知，其所警示的危險或惡害是否會實現，並非取決於行為人的意向（Wessels/Hettinger (Fn. 41), Rn. 402.）。例如，外交部因為越南的排華潮而對前往該地區旅客提出旅遊警告，或是動物園的老虎逃出，市政府警告民眾不要前往特定區域。

⁷⁴ 詳可參閱張天一，拿人錢財，不與人消災？——「類宗教行為」於詐欺罪上之問題／最高院100台上5493判決，台灣法學雜誌，234期，頁179以下（2013年）的判決整理及分析。德國文獻中，採肯定立場者，則如 Erich Samson, Grundprobleme des Betrugstatbestandes (1. Teil), JA 1978, S. 469 (471)。

操控該惡害是否實現的印象⁷⁵，以及（2）其所宣稱的惡害是否涉及到相對人的生命或身體。如果符合這兩項條件，便可評價成本罪的脅迫行為。反之，惡害內容如果只涉及到財產上的不利益（例如宣稱不遵從即會破財、失戀或是丟工作），依照本文前面肆、二、（一）所採擇的立場，則不會被認定成違反意願，便非屬本罪的脅迫行為。此外，這裡還有另一個值得進一步研究的問題：如果行為人所宣稱的神怪內容極為離譜（例如不與之發生性關係世界會立即毀滅，或是會發生星際大戰），無法取信於一般人，但被害人卻對此深信不疑，刑法是否仍應介入？依照通說，行為人所預示的惡害內容，也必須適於迫使一個審慎的人在具體情狀下順從行為人的要求⁷⁶。如果行為人所宣稱的內容極其離譜，一般人只會覺得可笑而不會相信，但被害人卻依舊深信不疑，刑法是否仍應提供保護，抑或應排除脅迫要素的該當？部分學者基於刑法補充性、被害人自我保護不足或是自我負責的思維，主張此時應排除構成要件的該當；但亦有文獻認為刑法仍應對於此類被害人提供保護，至於被害人自我保護不足的觀點，充其量也只會對行為人的量刑產生減輕刑罰的效果，而不會影響犯罪的成立⁷⁷。文獻上通常把這個問題放在詐欺罪的脈絡下討論（使用極為拙劣的詐術是否仍該當施行詐術要素），不過精確地說，這應該是所有犯罪類型都會出現的一般性問題，而非強制性交罪所特有，於此便不再繼續深入討論。

⁷⁵ 類似看法已見 *Träger/Altwater* (Fn. 22), § 240 Rn. 57.

⁷⁶ 僅參閱 *Geppert* (Fn. 22), S. 36.

⁷⁷ 參見 *Thomas Hillenkamp*, Unverstand und Aberglaube, in: *Amelung* (Hrsg.), *Strafrecht, Biorecht, Rechtsphilosophie* (Festschrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag), 2003, S. 135 (143)的學說整理。

伍、概括條款：其他違反被害人意願之方法

文獻上在討論概括條款時，經常會以脅迫或恐嚇的情形為例。這雖然和本文前面所提出的看法（例示概念亦須符合概括條款的內涵要求）不衝突，但概括條款必須有獨立於例示概念的適用範圍才有存在的實益，才不至於淪為贅文。這是在檢視各種判準時，必須要先具備的基礎認知。我們在前面參、以及肆、二、（一）已經提出了本文對「違反意願」要素的認定判準，也就是剝奪被害人是否從事（或忍受）性交的選擇自由。理論上，當然也可能基於相異的自由理解而提出其他判準，重點僅在於判準本身是否合乎事理、是否合於法條文義、是否充分明確，以及是否能夠順利嵌入現行法性犯罪規範的整體架構，而不至於架空其他條文或引起不同法規範之間的矛盾衝突。接下來，我們就把目光轉向國內文獻，看看學說上對於這個概括條款已經提出了哪些解釋建議，繼而再從各個判準本身以及性犯罪規範體系的觀點，逐一審視這些判準是否可行。

一、各種解釋建議

自1999年修法以來，學界對於違反意願這個概括條款提出了不少解讀建議。其中最為寬鬆的立場，就是將「違反意願」這個要素界定成日常口語中「非心甘情願」的意思，使其囊括一切足以影響被害人意願的行為，而不限於其意思自由受到強制、壓抑。依此，無論是基於何種因素而心不甘情不願地做成決定，都算是這裡所稱的「違反意願」⁷⁸。其次，亦有學者建議應透過「是否得有被害人的有效同意」來認定有無違反被害人意願⁷⁹，或是主張僅有行為人

78 見許玉秀，刑法對策（註60），頁284。與此類似者，如林大為（註71），頁119：被害人主觀上「不想」為此性交行為。

79 參見鄭逸哲（註19），頁37；林志潔、金孟華，美國女性主義法學發展與性侵害防制法之改革，月旦法學雜誌，182期，頁146（2010年）；涂春金、劉柏江（註71），頁55。另亦有學者雖然贊同此種立場，但認為必須透過修法，將「違反其意願」改成「未得其同意」才能解決問題，如李佳玟，違反罪刑法定的正

得到被害人「明示」的同意時，才能排除本罪的成立，以求能夠制裁那些利用被害人未置可否、半推半就的態度來遂行性交意圖的行為人⁸⁰。甚至有文獻更進一步主張，利用他人處於不具自由意識的狀態（如睡眠或昏迷）進行性交，如可認定其在自由意識狀態下將不會同意性行為，亦屬違反其意願而性交⁸¹。

另一方面，也有不少學者認為，本罪的「他法」若不以類似於所列舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等強制方法為必要，將會使本罪喪失強制（妨害自由）的本質⁸²，並且會架空乘機性交罪與利用權勢性交罪的適用空間⁸³。因此，法律適用者在解釋概括條款時，應該要受到前導例示概念牽制（限制性例示），讓概括條款仍保持妨害自由的性質。依照這種看法，透過概括條款來掌握的情形就必須與前導例示概念（強暴、脅迫）類似，限於被害人受到強制、性自主受到壓迫的情形⁸⁴，或是要求應限於與強暴、脅迫之強度相當的手段⁸⁵，甚至也有文獻主張修法後仍應以「至使不能抗拒」作為

義，台灣法學雜誌，160期，頁2（2010年）。美國威斯康辛州州法第940.225條「性侵害」（sexual assault），就是使用「未經同意」（without consent）的描述方式，有國內文獻指出此規定係採取了「基進女性主義」的理念，參見林志潔、金孟華（註79），頁157。關於基進女性主義對於性侵害的理解，可參閱陳昭如（註5），頁219以下、224以下的說明。

⁸⁰ 如林志潔、金孟華（註79），頁146。

⁸¹ 見柯耀程（註50），頁19。

⁸² 此見黃榮堅（註4），頁1834以下；盧映潔（註13），頁368。

⁸³ 此見甘添貴（註3），頁237。

⁸⁴ 採取此種立場者，如林山田（註57），頁225-226；甘添貴（註3），頁237-238；甘添貴，強制性交罪之評析與適用，收於：林山田編，刑法思潮之奔騰（韓忠謨教授紀念論文集），頁332（2000年）（以下簡稱：甘添貴，強制性交罪之評析）；陳子平（註64），頁207；林東茂（註71），頁2-68；高金桂（註19），頁256；許澤天（註53），頁124-125；吳耀宗（註64），頁17；錢建榮，重點在於有無違反意願的「方法」——為恐龍法官喊冤，台灣法學雜誌，174期，頁2（2011年）；薛智仁（註64），頁97。另曾淑瑜，刑法分則問題研析（二），頁98（2000年）似亦傾向此立場。另參見最高法院97年度台上字第4589號刑事判決：所稱「違反其意願之方法」，固不必達於使被害人不能抗拒之程度，但仍須具有妨害被害人之自由意志，違反被害人之意願而仍執意為之，始為相當。

⁸⁵ 盧映潔（註13），頁368。

要件⁸⁶，亦即，概括條款的新增只是一種宣示性的立法，立法者藉此並非想要創設新的可罰類型，而只是要提醒法官，妨害自由的事實認定途徑並不限於被害人的實際反抗動作，而是應該依照經驗法則去設想被害人所面臨的心理壓力。依此，概括條款僅具「指導解釋」的功能⁸⁷，也就是透過修法來導正法院認定事實的態度問題（見前文貳、）。另則有學者認為，修法後雖然不再要求已達不能抗拒，但行為人所使用的方法仍須「足使」他人陷入「不能抗拒」的狀態⁸⁸，或者是要求一種類似「優越支配」的低度強制手段⁸⁹。這些主張有著共同的大方向，就是希望能將1999年修法的影響降到最低，不讓本罪失去原本特殊強制類型的性質。最後，亦有部分學者建議參考德國刑法上性強制罪的新增規定作為概括條款的具體化方向，也就是把違反意願定義成：行為人利用被害人難以逃脫、反抗的無助狀態來遂行性交目的⁹⁰。例如，於深夜將被害人帶到人煙罕至的墓園，使被害人求助無門，被迫順從行為人的要求⁹¹。

86 見黃榮堅（註4），頁1811註68、頁1834。

87 此見黃榮堅（註4），頁1834以下。

88 如甘添貴（註3），頁237。類似主張亦見高金桂（註19），頁256：足以使被害人喪失抗拒能力或不敢抗拒的方法。

89 如李聖傑，妨害性自主：第三講，類型闡述，月旦法學教室，23期，頁104（2004年）（類似例示概念的「優越支配」）；王皇玉，引狼入室，月旦法學教室，87期，頁26（2009年）（以下稱：王皇玉，引狼入室）；王皇玉（註71），頁398以下、424（低度強制手段或低度強制程度）。類似看法，亦見陳子平（註64），頁207（判斷的重點應在於「行為強制性」的有無，而非被害人的反應）；許恒達，乘機襲胸案刑責再考——評台灣高等法院台中分院102年度侵上訴字第47號判決，台灣法學雜誌，233期，頁157（2013年）（應著眼於行為人的手法是否具備排除、壓抑、削減被害人反抗能力的效果，同時這個效果必須源自行為人的風險行動，而非源自被害人既存的反抗能力欠缺或減低狀態）。

90 如王皇玉，引狼入室（註89），頁26；王皇玉（註71），頁424；許澤天（註53），頁124；許恒達（註89），頁158。甚至最高法院的部分判決亦曾提及類似觀點，如最高法院100年度台上字第4578號刑事判決：惟強制猥褻罪係以學理上所謂之「低度強制手段」妨害被害人之意思自由，違反被害人之意願所為，並非完全不要求強制手段之實行，所謂「低度強制手段」，係指行為人縱未施強暴、脅迫、恐嚇、催眠術，但只要行為人製造一個使被害人處於無助而難以反抗、不敢反抗或難以逃脫之狀態，達於妨害被害人之意思自由者，即屬之。

91 例見許恒達（註89），頁158。

在新法甫生效時，最高法院曾經一度有部分判決支持前述要求強制性質的看法⁹²，待該院做成97年度第5次刑事庭會議決議後⁹³，實務見解便大致定調，不再採取該種解釋立場⁹⁴。然而，由於該決議並沒有正面對於概括條款提出任何判準，因此很難進一步認定最高法院另採何種立場。不過，歸納該院適用概括條款的大宗案例來看，至少已可看出一個傾向，就是將概括條款適用於行為人利用被害人的宗教信仰遂行性交意圖的案例⁹⁵，文獻上亦不乏支持此種看法者⁹⁶。

在上述各種解釋建議的背後，可以隱約看到兩股相互較勁制衡的對立思維。一方面，法律應當提供被害人最佳的保障，在應然面擔保所有人都不會被追從事性行為。但在另一方面，法官也必須避免誤判，這點對於具有隱密特性的性犯罪來說尤其困難。因此，我們才會在構成要件的設計和解釋上提出較多的客觀要求，以避免在

92 如最高法院96年度台上字第6736號刑事判決：……故在解釋強制猥褻罪中所謂「其他違反其意願之方法」時，自不得僅以為著重於保護被害人之意願，不論行為者施用何種手段，只要係以違反被害人意願之方式而為之猥褻行為，即成立本罪。是本條所謂「其他違反其意願之方法」，似應指行為人仍應有與條文列舉之所謂強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等相當之其他強制方法，足以壓制被害人人性自主決定權，始足當之，而非祇要行為人以任何違反被害人意願之方法而為猥褻行為者，均構成刑法妨害性自主罪章之強制猥褻罪。

93 該決議明白指出：修正後所稱其他「違反其意願之方法」，應係指該條所列舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術以外，其他一切違反被害人意願之方法，妨害被害人之意思自由者而言，不以類似於所列舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等相當之其他強制方法，足以壓抑被害人之性自主決定權為必要，始符立法本旨。

94 參見最高法院97年度台上字第5814號刑事判決（祇要達於妨害被害人之意思自由者，即合於「違反其意願」之要件）、最高法院97年度台上字第6117號刑事判決（祇須所施用之方法違反被害人之意願，足以壓抑被害人之性自主決定權者，即足當之），以及最高法院102年度台上字第3692號刑事判決（祇要行為人主觀上具備侵害被害人人性自主之行使、維護，以足使被害人人性自主決定意願受妨害之任何手段，均屬之）。

95 如最高法院101年度台上字第1087號、101年度台上字第3973號、102年度台上字第2200號等刑事判決。

96 如許玉秀（註7），頁32；王皇玉（註71），頁421以下、425；林大為（註71），頁119以下。反對者則如甘添貴，強制性交罪之評析（註84），頁332。

被害人事後變卦惡意誣陷被告的情形，法官因採信片面之詞而誤判。接下來，我們就逐一檢視這些主張，最後再提出本文的看法。

二、保護意思決定不受干擾？

強制性交罪的本質，就是被害人被迫違反自身意願去從事（或忍受）性交行為⁹⁷，也就是「非自願的參與性接觸」（die unfreiwillige Beteiligung am Sexualkontakt）⁹⁸，是一種妨害自由法益的犯罪類型⁹⁹，所侵害的是被害人在性方面的自主決定權，現今學界對此已有高度的共識。問題只在於，立法技術上要如何描述，才能精準表達這種扭曲意願（willensbeugend）的性質。我國的立法者選擇直接使用「違反被害人意願」來當作構成要件要素，這樣的表述當然完全契合本罪的禁制核心¹⁰⁰，因為這就是直接把立法動機拿來當作成罪的要件。然而，「意願」是個純粹主觀的概念，立法者直接使用「違反意願」這樣的表述，如果解釋時又沒有再進一步具體化、客觀化，勢必就會讓法律的適用淪於法官或告訴人的恣意，難以擔保法安定性¹⁰¹。在上個世紀末期，德國立法者也曾考慮過是否要直接將「違背意願」（gegen den Willen）放入構成要件

97 參閱Fischer (Fn. 28), § 177 Rn. 4.

98 此係參考Isfen (Fn. 10), S. 231 f. 的用語。

99 這是國內刑法學界相當一致的看法，僅參閱林山田（註57），頁220；甘添貴（註3），頁234；德國學界亦同，僅參閱Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf (Fn. 46), 10/12.

100 徐偉群（註5），頁2：被害人的「性自主決定」根本上就是被害人的一種心智狀態，因此「違反被害人意願」這個要件的必要性與正當性就在於，它就是法律禁制的核心。在這裡，法官的工作本來就是要辨識出被害人在行為人行為當時是否處於違反自己意願的狀態，否則他根本無從論斷行為人是否犯了強制性交罪。

101 在故意與過失的區分難題史上，通說亦主張用心理學意義下的意欲當作區分標準。從德國與臺灣的實務操作已經可以輕易看到，把個人的內心意願（像是容任、同意或接受這些心理狀態）拿來當作法律要件，有多容易淪為法律適用者恣意操控的巧門，對法律適用的安定性會造成多大的傷害。對此可參閱徐育安，故意認定之理論與實務，中研院法學期刊，10期，頁134以下（2012年）的整理。

中。經過反覆討論，最後還是基於憲法上的理由放棄了這種立法模式，認為不能讓成罪與否單純取決於被害人的內在意思，而必須要求外顯的客觀根據¹⁰²。甚至有學者指出，若是成罪要件置重於被害人的意思方向，將會使被害人在訴訟程序中成為雙方攻防的焦點，會去探討分析其過往的性經驗或行為習慣，容易造成被害人的二度傷害¹⁰³。但既然我國實定法已經做了這樣的描述，法律適用者就必須進一步具體化這個要素的內涵。

要確認有無違反被害人的意願，自然就要先澄清「意願」的內涵。這裡的意願，從性自主決定權的本質來看，應該是指被害人要不要在該時、該地與行為人以該種方式從事性交行為的意思決定¹⁰⁴。由於這是一種內心意向，最直接的想法就是看被害人是否「心甘情願」，也就是文獻上最寬鬆的立場；只有當被害人的性交決定沒有受到行為人干擾，才是出於自願，才不會構成本罪。這樣的理解雖然合於一般人的語言使用習慣，也能滿足立法者希望擴大本罪適用範圍的修法企圖，但卻沒能讓構成要件的內涵更具體，甚至

102 參閱Thomas Fischer, Sexuelle Selbstbestimmung in schutzloser Lage, ZStW 112 (2000), S. 75 (76 f.) 所整理的修法過程。對於直接將違反意願拿來作為構成要件要素的批評，亦見Isfen (Fn. 10), S. 227：如此不但會提升證明的困難度，也容易讓行為人形成構成要件錯誤。同樣反對用內在情境作為成罪要件的Hörnle教授則是提出另一個面向的思考：有時候因為性接觸周邊條件在情緒或社交文化上的複雜性，於行為當下精準描繪出自己的真實意願已非易事，取證時間的間隔也可能會影響到證詞的可靠度，因為性接觸並非總是在自己身體和精神都很清醒的狀態下發生，而且人們有時也會因為後續的發展，而不自覺地重新調整自己的感受（Hörnle (Fn. 55), S. 319.）。

103 參閱Isfen (Fn. 10), S. 230。另一個值得探討的問題，則是在訴訟上，用被害人的職業或過往素行來推斷其行為時的意思方向是否妥適？二者間是否（以及在多大的程度上）存有證明關聯性？

104 見Fischer (Fn. 102), S. 87。在刑法的脈絡下，所謂的性自主決定權並非指積極自由意義下的性自主，亦即，刑法並不是要保護個人根據自身願望去形塑性生活的積極自由，而是提供個人消極的防禦權（Abwehrrecht），也就是免於他主干涉的自由。透過強制性交罪，國家擔保每個人得以自行決定是否以及透過何種方式在特定時間地點從事或不從事性行為，此見Hörnle (Fn. 28), Vor § 174 Rn. 28; Laubenthal (Fn. 2), Rn. 29.

還會引發新問題。詳言之，受到強制其實是伴隨人類存有的現象¹⁰⁵，我們只要活在世上，就會持續受到各種（自然或社會的）條件所壓迫。因此，人類的一切決定本來就不會是絕對的自由，而只可能是相對自由，也就是「剩餘自由中的自由」（*Freiheit in der Restfreiheit*）¹⁰⁶。我們甚至可以說，人類的每個行動決定都是在交換各種資源，都是在各種因素（如生理或經濟等環境條件）的交互影響作用下，評估各種不同決定所可能帶來的正面及負面效應後做成，多少都會有不盡如意、不太甘願的地方。所謂的「不甘願」，其實只是個人在忍受行動決定的負面效應時，附隨出現的片面情緒而已，並非從事該行動的意願本身¹⁰⁷。用這樣的情緒來決定犯罪的成立，要不就是會將一切帶有條件交換性質的性行為全面入罪，變相地限制性行為雙方當事人的利益處分自由¹⁰⁸；不然就是會讓成罪與否取決於法官或被害人的恣意，嚴重影響法安定性。

最後，從規範體系的角度來看，如此寬鬆的解釋也會導致相當怪異的結果，亦即，刑法第228條（利用權勢性交罪）將會完全被強制性交罪所包含¹⁰⁹，進而使得前者成為後者的「減輕」構成要

105 Rönnaу (Fn. 20), S. 436; Thomas Rönnaу, Voraussetzungen und Grenzen der Einwilligung im Strafrecht, Jura 2002, S. 665 (674) (以下簡稱：Rönnaу, Voraussetzungen).

106 語見Rönnaу (Fn. 20), S. 230 f., 436。依此，法律只能擔保每個人的剩餘自由不會被他人進一步惡化；強制罪所要禁止的，就是行為人惡化被害人在法律上受擔保的自由空間。

107 此見周漾沂，風險承擔作為阻卻不法事由，中研院法學期刊，14期，頁207（2014年），不過該文的討論脈絡為容許風險的判斷問題。

108 放棄自己持有的利益，也是一種實現自由的表述，此見Thomas Rönnaу, Die Einwilligung als Instrument der Freiheitsbetätigung, Jura 2002, S. 595 (598)。另參照上文肆、二、（一）關於「交換禁令」的說明。

109 前提當然是在解釋刑法第228條的構成要件時，將之限縮於行為人「濫用」特定監督、扶助、照護關係以促成性交行為的情形。現行刑法第228條第1項條文描述過寬，就連像是醫師利用診療機會追求病患，兩人在兩情相悅下發生性關係的情形，形式上也會該當條文中所稱之「利用醫療機會與因醫療關係受自己照護之人為性交」，不合理處不言而喻。

件¹¹⁰。然而，我們實在找不出任何理由能夠正當化這樣的體系理解，因為該罪所要非難的是行為人濫用其與被害人之間的特殊照護指導關係，不可能由此導出不法或罪責內涵「降低」的結論¹¹¹。

三、未獲同意＝違反意願？

由於立法者明文將被害人的對立意志（der entgegenstehende Wille）加入本罪的構成要件中當作一個形式要件，本罪便成為一種所謂形式上破壞意志的犯罪（die sog. formalen Willensbruchdelikte）¹¹²。在這種類型的犯罪中，法益持有者的處分自由一併化作構成要件要素，因此，行為人若得有法益持有者的有效同意，自然就會排除構成要件的該當，這就是所謂「阻卻構成要件的同意」（tatbestandsausschließendes Einverständnis）¹¹³。在本罪的脈絡下，當行為人得到被害人有效的性交同意時，便阻卻「違反其意願」要素的該當¹¹⁴。到此為止學說上並無異論，但我們是否可以如部分文獻所主張，從「未取得有效之同意」導出「違反被害人意願」的結論？

將未獲同意等同違反意願的解釋立場，宣稱如此可讓被害人的

110 但另有文獻認為修法後，乘機性交罪、利用權勢性交罪與詐術性交罪都會失去適用的空間，見甘添貴（註3），頁237。

111 立法者原先制定利用權勢性交罪的想法正好與此相反，就是因為行為人濫用這樣的特殊關係值得非難，即便不構成舊法的強姦罪，也還是要另行立法來加以處罰。

112 用語參考自Rönnau (Fn. 20), S. 12 f.

113 至於在同意的有效性要件方面，受到詐術欺瞞或強制影響的同意是否必然會因該意思瑕疵而失效，學說上有不同看法。鑑於每個構成要件的设计均有所不同，意思瑕疵對於同意有效性的影響便也會互有差異。依照德國通說看法，即便是同屬侵害意思形成自由與意思驅動自由的強制罪與強制性交罪，其同意的有效性要件亦非相同（僅參閱Theodor Lenckner/Detlev Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., 2014, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 32 f.）。

114 在德國法上，同意則是阻卻性強制罪條文中的「強制」（nötigen）要素，僅參閱Renzikowski (Fn. 27), § 177 Rn. 50.

性自主決定意思獲得最充分的保障。就被害人未注意到行為人的性侵入行為（如下文之【例4】）、被害人來不及反應或是未置可否、半推半就等情形來說，固然是如此；因為依照這種主張，只要未獲相對人的正面同意，行為人便會構成本罪。但是這樣的法律適用結果恐已逸脫法條的文義範圍，而會牴觸罪刑法定原則。詳言之，關於性強制犯罪的立法模式，在大方向上可分成「只有可以才行」（only yes means yes; nur ein Ja ist ein Ja）以及「只有不可以才不行」（only no means no; nur ein Nein ist ein Nein）這兩種選項。我國現行法選擇了後者，置重於被害人的反對意思被壓制；而主張未獲同意即成立犯罪者，則是支持第一種模式。因為這兩種模式在文字意涵上並非完全相同，法律適用者自然無權自行變更立法者的模式選擇。依照一般的語意理解，「違反意願」應以相對人已經表示了不接受的意思（但被行為人蔑視、罔顧）為前提¹¹⁵，但「未獲同意」則不限於此，還另包含了相對人未及反應或未置可否的情形。基此，從「欠缺有效同意」乙點，應該只能推導出「不會基於同意排除構成要件該當性」的結論，但無法再進一步得出「違反意願」要素的該當。否則，若是貫徹這樣的解讀，那麼對一個三個月大的嬰兒也就也能夠成立強制性交罪，儘管這名嬰兒對於與性相關的事務完全沒有任何意識可言¹¹⁶。要能稱得上意願被侵害，當然是以被害人原本能夠形成相關的意願為前提。就好像要能稱得上財產受到損害，前提當然是原先擁有財產；具有自主決定意思，才會有性自主決定意思被侵害的可能。

115 正因為如此，學說上在定義竊盜罪的竊取要素時，才會將「違反持有人意思」與「未得持有人同意」二者並列。

116 學說咸認為嬰兒並非強制性交罪的適格被害人，參閱黃榮堅（註4），頁1810、1835-1836；鄭逸哲（註19），頁37以下。但最高法院99年度第7次刑事庭會議決議（理由三、）卻認為，如果涉及到未滿7歲的被害人，自應由保護幼童的角度來解釋，「不必拘泥於行為人必須有實行具體之違反被害人意願之方法行為」。這樣的解釋明顯牴觸罪刑法定原則，因其明白表示刑罰法律的解釋可以不受法條文義所拘束。

另外，這種解釋立場也會引發體系上與其他條文的相容性問題，像是會架空刑法第225條第1項（乘機性交罪）。詳言之，在諸多被害人不知或不能抗拒的情形，被害人根本就失去了意思形成能力（例如處於泥醉狀態），本質上必然欠缺有效的積極同意。更有甚者，若將如此的解釋套用到違反意願猥褻罪（刑法第224條）的概括條款，也會讓該罪的適用範圍涵蓋到那些趁人不知或不及防備的突襲式觸摸行為，進而架空性騷擾防治法第25條第1項的突襲觸摸罪¹¹⁷。

最後，即便撇開這種主張業已逾越法條文義（改變立法模式）以及會造成規範體系內部衝突等問題，若是僅限於明示的同意才能排除本罪的成立¹¹⁸，除了偏離於同意的一般法理外¹¹⁹，也會讓本罪的適用範圍不當地擴及當事人間存有默示同意的情形。從現實面觀察，大部分的性接觸行為在開始前，參與者都沒有先取得對方的明示同意，而是透過肢體動作來表達默示（可得推知）的同意。在雙方都透過動作間接表達了性接觸意願時，即便沒有明示的同意表示，也不會有任何一方性自主決定受到侵害的問題。但上開的解釋卻有可能於此亦得出違反意願的結論，造成本罪處罰範圍不當地膨脹¹²⁰，最後變成透過刑罰來維護性行為的「要式性」！更何況，性

¹¹⁷ 依照現行法及學理，這種趁人不及防備的突襲式觸摸行為應透過性騷擾防治法第25條第1項來掌握，而非論以強制猥褻罪，僅參閱林東茂（註71），頁2-72；王皇玉，引狼入室（註89），頁26；以及最高法院100年度台上字第4578號刑事判決。與此相對，德國法上並沒有相類的處罰規定，已有不少學者指出，這種突襲式攻擊（Überrumpelung）是個亟待填補的處罰漏洞，僅參閱 *Isfen* (Fn. 10), S. 218; *Hörnle* (Fn. 55), S. 320.

¹¹⁸ 見林志潔、金孟華（註79），頁146。

¹¹⁹ 依照通說，阻卻構成要件的同意亦包括默示，甚至無須表示於外，只要於行為時事實上存在此種有意識的同意即可，僅參閱林山田，*刑法通論（上）*，10版，頁369（2008年）；*Johannes Wessels/Werner Beulke/Hellmut Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil*, 44. Aufl., 2014, Rn. 368.

¹²⁰ 類似批評亦見 *Isfen* (Fn. 10), S. 229。因此，已有文獻主張，即便要採強調同意的立法模式，亦應包括默示的允許，如 *Hörnle* (Fn. 55), S. 320。但其亦同時指出，這種強調同意的模式會讓性犯罪既有的證明問題更形複雜（*Hörnle* (Fn.

活動往往不僅只是單一的舉動，倘若每個階段都必須重新獲得明示的允許，現實生活中的可行性恐怕不高¹²¹。性接觸的互動過程先天上就是沒有固定的形式，而且摻雜了大量情緒性、自發性的情境變因。上述這種冷靜且高度自制的行止要求，賦予性接觸的參與者必須持續確認對方是否同意（而非注意對方是否有反對、拒絕的表示）的義務，是否適於作為性活動領域的行為指導規範，仍有待進一步思考斟酌¹²²。

四、陷於錯誤＝違反意願？

前面已提過，最高法院向來主張本罪的概括條款可適用於所謂「宗教騙色」的行為¹²³。這種立場在文獻上也獲得不少支持，甚至進一步演繹成：陷於錯誤即屬違反其意願¹²⁴。接著，我們就來檢視這樣的說法是否站得住腳。

如前段所言，被害人的有效同意可以阻卻本罪構成要件的該當。但如果法益持有者的同意是在錯誤的認知基礎上做成，甚至是因行為人施詐所促成，該同意是否仍有效？由於人類的認知能力有其侷限性，每個人都必然是在資訊不足（甚至有誤）的基礎上做出決定¹²⁵，而不可能全知全能、不發生任何錯誤。因此可以先確定的是，並非所有錯誤都會排除同意的自主性。特別是在法益持有者自己發生錯誤，並且基於該錯誤想像做成同意的情形，最為明顯（例如：誤以為對方為商業鉅子而決定與之發生性關係）。但在另一方

55), S. 321)。

121 已見Hörnle (Fn. 55), S. 320.

122 見Isfen (Fn. 10), S. 229。這一點同時也是立法者在「只有可以才行」與「只有不可以才不行」兩種模式間抉擇時，應該仔細思考的關鍵環節之一。對於不同立法模式的利弊分析，可參閱Isfen (Fn. 10), S. 228 f.; Hörnle (Fn. 55), S. 317 ff., 320.

123 見前註68與69的判決整理。

124 如林大為（註71），頁125以下。

125 參閱Rönnau, Voraussetzungen (Fn. 105), S. 672.

面，被害人也有可能因為錯誤而對於受侵害的法益種類、侵害方式或侵害範圍欠缺正確且完整的認知，也就是發生所謂「與法益相關」(rechtsgutsbezogen)的錯誤類型¹²⁶。由此可知，在「法益持有者基於錯誤而同意」這個標題下，其實囊括了諸多不同態樣，法律上的評價自然無法一概而論。文獻上另有建議應區分「具恐嚇性質之詐術」以及「不具恐嚇性質之詐術」兩種次類型¹²⁷，但具恐嚇性質的詐術類型應該置於例示概念「脅迫」的脈絡中處理，而和概括條款的適用無關。因此，以下的討論僅針對不具脅迫恐嚇性質的施詐類型，我們就先從「與法益相關」的錯誤類型談起。

(一) 與法益相關的錯誤

性行為的同意要能產生阻卻構成要件的效果，必須同意者對於促成同意的相關基礎事實、利益損失的範圍及後果均有所瞭解，並且也知悉在接受侵害之外的其他選項等重要事實，在如此前提下所做成的決定，才可能被評價成自主的決定¹²⁸。反之，一個人若是不知道自己放棄了什麼、不知道行為人的行為會造成何種型態及程度的侵害，就稱不上是在行使自己的處分自由¹²⁹。像是：

【例4】被害人甲同意婦產科醫師乙進行內診，但乙卻趁甲不知，暗中使用舌頭及性器官進入甲的性器官（最高法院98年度台上字第3312號刑事判決案件事實）。

本案的被害人在答應接受內診的當下，並不知道醫師會將舌頭及性器官伸入自己的性器官，因此係處於與法益相關的錯誤中。依

126 這個概念原本是在討論「承諾有效性」的脈絡下被提出，僅參閱 *Bernd Heinrich*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., 2014, Rn. 468 ff.; 國內文獻則可參考吳耀宗，被害人受騙之承諾，月旦法學教室，126期，頁29（2013年）。

127 參見王皇玉（註71），頁408以下。

128 參閱 *Rönnau* (Fn. 20), S. 219.

129 *Rönnau* (Fn. 20), S. 227, 454; *Rönnau*, *Voraussetzungen* (Fn. 105), S. 671.

照通說看法，此處被害人的同意因重大瑕疵而無效¹³⁰。然而，處於此類錯誤中的被害人事實上並沒有對於不知情的部分做出任何處分，應該沒有同意可言，自然也就沒有同意是否有效的問題，通說的說法似乎不夠精準¹³¹。依此，本案被害人對於正常的內診部分所做的同意仍屬有效，至於行為人超出內診範圍的行為，則自始未受有任何同意。最高法院在本案肯定了概括條款的適用，認定成立強制性交罪，文獻上亦不乏贊同此結論者¹³²。然而，這樣的論罪似嫌速斷。被害人雖然對於醫師的性交行為並無同意，但即便如此，單從「欠缺有效同意」這一點也只能推出「不會排除構成要件該當性」的結論，而不能再進一步肯定「違反意願」要素的該當（見前文伍、三、）。事實上，由於被害人對於行為人所為的性交行為根本無所知，自然不會形成任何具體的贊成或反對意思；隨而，趁此狀態遂行性交意圖的行為人也就不會成立（以壓制被害人具體反對意志為要件的）強制性交罪。在日本，則是透過與我國刑法第225條第1項（乘機性交罪）相似的第178條第2項來掌握【例4】的情形¹³³。就行為所侵害的法益來看，如此的論罪可資贊同，因為行為

130 僅參閱Murmman (Fn. 29), 25/129.

131 此批評已見Günther Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1991, 7/117; Thomas Rönnau, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2006, Vor § 32 Rn. 199; Rönnau (Fn. 20), S. 410, 454.

132 如許玉秀（註7），頁32、35；王皇玉（註71），頁422-423。

133 參閱西田典之著，王昭武、劉明祥譯，日本刑法各論，頁113（2012年）；山口厚著，王昭武譯，刑法各論，頁126（2011年），以及廖宜寧，乘機性交猥褻罪的規範適用問題——以精神障礙者之性自主權利為中心，頁23-24（2014年）的整理。日本刑法第178條雖然在該國被稱為「準強制猥褻強姦罪」，但觀其內容，與我國刑法中過去同樣被稱為準強制性交猥褻罪的第227條（與幼童性交猥褻罪）截然不同，而是近似於我國刑法第225條的乘機性交猥褻罪。該條第1項規定：「乘他人心神喪失或不能抗拒，或使他人心神喪失或不能抗拒而為猥褻行為者，依第176條（強制猥褻罪）之例處斷」。同條第2項則規定：「乘女子心神喪失或不能抗拒，或使其心神喪失或不能抗拒而為姦淫行為者，依前條（強姦罪）之例處斷」。於此應特別注意，前開條文中未用粗楷體字標示的行為模式（使他人心神喪失或不能抗拒），在我國刑法中則是透過強制性交罪來掌握，而非乘機性交罪。其次，在粗楷體字的部分，沒有列入「不知抗拒」的類型，也沒有限定不能抗拒的形成原因，這些則是異於我國刑

人雖然沒有壓抑被害人的實際自由意志，但卻侵害了她的性自主決定權（是否與行為人從事性交的決定可能性），這正是透過乘機性交罪所要防止的情形。但是在我國法中，由於立法者對於被害人不能或不知抗拒的形成原因設有限制（利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒），這樣的案例事實能否該當「利用其他相類情形不知抗拒」的類型，還有討論的空間，取決於我們如何界定例示概念之間的類似特性¹³⁴。此外，也有學者認為本例中的行為人應成立刑法第228條第1項的利用權勢性交罪¹³⁵。然而，本案行為人固然是利用醫療照護的機會，但被害人根本不知道性交事實，是否仍可該當利用權勢機會性交的構成要件，恐怕也還是有不小的爭論空間。有鑑於這些都是需要獨立處理的問題，本文就此打住。但無論如何至少可以確定，這樣的事實稱不上違反被害人意願¹³⁶。

（二）其他的錯誤

被害人如果對於法益侵害的種類、方式、範圍或危險性有正確且完整的認知，只是對於其他非與法益相關的事項（例如：性交易的對待給付、相對人的結婚意願或實際身價等）受到欺瞞，則行為人透過詐術僅影響到相對人的行為動機，學說多認為並無違反意願可言¹³⁷。另有少數文獻主張，此時仍可基於施行詐術而肯定強制性

法第225條之處。

¹³⁴ 倘若將重點置於「被害人正處於一個無法或難以擷取意願的狀態」（如盧映潔（註13），頁390），本例事實自然就難以該當乘機性交罪的構成要件，進而產生一個亟待填補的處罰漏洞。不過在此也應當一併思考的是，立法政策上有無必要對於不能或不知抗拒的形成原因附加限制。像是日本刑法第178條（條文內容請見前註），便沒有對於不能抗拒的形成原因附加任何限制，對於性自主的保護自然更為周全。

¹³⁵ 如黃惠婷（註17），頁229；許玉秀（註7），頁30。

¹³⁶ 相同見解已見黃惠婷（註17），頁225。

¹³⁷ 如林山田，刑法的革新，頁266（2001年）；林山田（註57），頁227；黃榮堅（註4），頁1837；盧映潔（註13），頁368；王皇玉（註71），頁422；涂春金、劉柏江（註71），頁55。

交罪的成立，主要的論據就是：行為人若是知道實情便不會同意性交，因此係屬違反意願¹³⁸。關於此處的爭論，應以多數說的立場為當，理由分述於下。

首先，依照通說看法，「同意」本質上是一種事實，只要實際存在便可阻卻構成要件的該當；即使具有意思瑕疵，或者同意的動機極不理性或不道德，均不影響其效力¹³⁹。若是於事實存在之外再加上其他的有效性要件，將會牴觸罪刑法定原則¹⁴⁰。這也正是詐欺取財的行為人不會同時構成竊盜罪的原因，受騙的被害人雖然是因為遭受欺瞞才會交付財物，但畢竟事實上已經做出一個移轉持有的同意，所以不會該當竊取要素。罪刑法定原則對於構成要件劃出了一條不得逾越的界限，不允許法律適用者超脫法條文義做出不利於行為人的結論。更何況，若是將承諾的有效性要件也套用到同意，致使違法或違反風俗道德的同意均歸於無效，那麼通姦行為也就同時會構成強制性交罪，不合理之處至為顯然¹⁴¹。

至於少數說所言，被害人若是知道實情就會做出反對的意思表

138 如林大為（註71），頁125以下。日本實務界對於此種類型的處理，則有相互對立的判決，參見前田雅英著，董璠興譯，日本刑法各論，頁105（2000年）的介紹。在加拿大亦有類似的法律解釋，據報載，加拿大男子Craig Jaret Hutchinson想留住女友，便暗中用針將保險套刺破，再與女友性交。女友懷孕後憤而提告，加拿大法院於2009年依加重性侵罪判刑18個月。全案經上訴後，最高法院於2014年的判決中指出，被告此舉形同詐欺，等於在未經被害人同意下發生不安全性行為，維持了原有罪判決（參閱陳怡姣，嘿咻刺破保險套 害女懷孕判性侵，蘋果日報，2014年3月9日A26版）。

139 僅參見Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 119), Rn. 367; Fischer (Fn. 102), S. 89.

140 參閱Henning Rosenau, in: Satzger/Schmitt/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 2009, Vor §§ 32 ff. Rn. 43。亦有學者將相關罪名進一步區分出不同類型，並賦予各自相異的有效性要件（如Kindhäuser (Fn. 72), Vor § 13 Rn. 194 ff.），但在壓制被害人對立意願（Überwindung eines entgegenstehenden Opferwillens）的犯罪類型，意思瑕疵也還是不會影響同意的效力，事實上存在的同意仍能阻卻構成要件（Kindhäuser, (Fn. 72), Rn. 206.）。

141 參閱Detlev Sternberg-Lieben, Die objektiven Schranken der Einwilligung im Strafrecht, 1997, S. 200 ff.

示，這也只是在說明詐術行為與同意之間具有因果關係，而不足以證立同意的無效¹⁴²。否則，隱瞞自己患有性病的事實與他人性交（刑法第285條）或是自始打算賴帳的性交易當事人就也都會成立強制性交罪。然而，在交換行為中（如性交易），相對人不給付的風險並不會剝奪受騙者的行為自由，在這種錯誤的基礎上所做出的性交同意仍具自主性；縱使被害人嗣後對於行為人所允諾的對待給付失望或期待全部落空，亦然¹⁴³。既然此時仍存有一個有效的同意，自然就沒有反對意思可言，也就不會該當違反意願這個要素。從時間的面向來看，也會得出相同結論：法益持有者作成同意的動機事後未能實現，並不會溯及地讓自己行為時所做成接受性交的意思表示失效¹⁴⁴。更不用說，有些被害人在旁人告知真相後，仍然執意相信行為人。如果用被害人事後的信或不信來認定有無違反意願，則顯然已經不是考量「行為當時」的被害人意願，恐與犯罪成立的基本原則有所扞格。依此，行為人即便自始隱瞞內心想賴帳的真意而促成性交易，也不會成立強制性交罪，因為此時性自主決定權並沒有受到戕害，充其量也只是財產上的侵害¹⁴⁵。讓被害人不會做出將來會後悔的性交決定，絕非刑法的任務。

142 更不用說從「欠缺同意」也無法直接導出「違反其意願」的結論，詳見前文伍、三、的說明。

143 Fischer (Fn. 102), S. 83, 85. 學說在承諾有效性的討論脈絡下所提出的規範性自主理論 (normative Autonomietheorie) 亦有類似的思考。依照該理論，若從規範的角度來看，事件仍屬法益持有者的自主表述、仍可評價成其行為自由的實現時，承諾即屬有效，參見Roxin (Fn. 21), 13/99.

144 最高法院已有判決明白採取相同看法，如最高法院102年度台上字第248號刑事判決：對於男女施用詐術，使陷於錯誤而同意為性交，行為人無施以強制力自明，又被詐欺者之同意固有瑕疵，然就形成決定之心理狀態觀之，仍本於個人自由意思，並無違反意願可言，自不成立強制性交罪。否則，刑法第221條第1項強制性交罪，應無不將詐術例示為違反意願方法之理。同法第229條第1項之詐術性交罪，亦無另定處罰必要。

145 至於是否構成詐欺得利罪，則另涉及到財產概念（純經濟的財產概念 vs. 法律·經濟折衷的財產概念）的爭議，詳參閱黃榮堅，刑法問題與利益思考，頁93以下（1995年）。

最後，還要提出一個體系解釋觀點下的輔助論據。刑法第231條第1項對於「使用詐術」促使他人為性交或猥褻行為設有處罰的規定，而在第231條之1第1項則是對於「以強暴、脅迫、恐嚇、監控、藥劑、催眠術或其他違反本人意願之方法」促使他人為性交或猥褻行為設有處罰規定。同樣的情形也出現在人口販運防制法第2條、第32條第1項及第34條第1項，詐術和違反意願均並列成兩個選擇要素。更有甚者，兒童及少年性剝削防制條例第34條第1項後段將「詐術」列為基本構成要件的行為模式選項之一，同條第2項則是將「強暴、脅迫、恐嚇、監控、藥劑、催眠術或其他違反本人意願之方法」列為加重其刑至二分之一的行為選項。如果把施行詐術等同（或是包含於）違反意願之手段，將會在上述的條文引發規範邏輯上的混亂。

綜上所述可知，無論相對人的錯誤是發生在與法益相關的事項還是其他環節，都無法從陷於錯誤的狀態推導出違反意願要素的該當。因此，用陷於錯誤來認定違反意願的解釋建議，在內容和法規範體系上都站不住腳。

五、與例示概念相當的強制手段？

（一）強暴與脅迫外的強制手段？

如前所述，在本罪修法後，仍有不少學者主張概括條款應限於被害人受到強制的情形。這種立場最符合法條中的「其他」一詞¹⁴⁶，並且維持了本罪妨害自由的固有一貫本質。不過，要能夠貫徹這樣的解釋立場，前提當然是在這些前導例示概念之外，還有其他妨害自由的強制行為態樣存在。然而，我們若是同時對照刑法第304條第1項強制罪構成要件就會發現，依照立法者的評價，刑法上應

¹⁴⁶ 透過「其他」一詞，讓例示概念與概括條款二者相互影響及牽制，見前文參、及下文伍、六、（一）的分析。

罰的妨害自由行為就是強暴與脅迫這兩種態樣。在刑法第221條第1項的構成要件中，立法者透過前導例示概念其實就已經窮舉了強制罪所列出的所有強制手段，隨而在解釋「其他方法」時，自然就只能尋找這些強制行為態樣以外的方式。其實，這個問題早在舊法時期便已存在，因為舊法強姦罪在強暴與脅迫之外，也同樣並列了「藥劑、催眠術或他法」¹⁴⁷。如果在強暴與脅迫之外，還有其他可以致被害人不能抗拒的強制方法，當行為人使用這些其他方法時，就不會同時該當強制罪¹⁴⁸。我們若是堅持概括條款掌握的情形也必須具有妨害自由的性質，在技術上就會先遭遇到這個問題。

但是在另一方面，如果一定要限於行為人有具體實行強暴或脅迫的行為才能成立本罪，那麼當被害人身處於任憑行為人宰制的無助處境（die schutzlose Lage）時，則又會產生不合理的處罰漏洞，像是：

【例5】行為人原本只打算擄人勒贖而將被害人置於自己的監禁下，隨後竟起了色心，想要與之從事性交。被害人內心雖不願意，但因為籠罩著暴力氛圍，擔心若拒絕將會遭到毆打，便乖乖就範。

如果被害人已經陷入極度恐懼（甚至已被嚇呆），或是因為環境、體力上的劣勢（先前遭到挾持而處於行為人的支配下）而未反

¹⁴⁷ 舊法時期的教科書中，關於「他法」所舉之例，像是勸酒使人泥醉（見黃東熊（註9），頁335；高金桂（註19），頁256），或是聲稱神明附體迫使對方聽任其姦淫（此見梁恆昌，刑法各論，11版，頁217（1986年）；呂有文，刑法各論，2版，頁203（1987年））。但前者已屬剝奪他人意思形成能力的強暴（詳見前文肆、一、），後者則與修法後的實務立場一致，相關討論詳見前文肆、二、（二）。

¹⁴⁸ 前提是這兩個條文中的強暴與脅迫概念均採相同的解釋。技術上當然也可以讓強暴與脅迫在不同的條文中取得不同的內涵，因學說上早已揚棄機械式的法律概念一致性要求，改採法律概念相對性的立場，但最重要的是，必須要能夠說得出區別處理的實質依據，以證立差別對待的正當性。

抗，行為人自然毋需再額外施行任何的強制行為，即可遂行其性交目的。此時行為人只是單純地利用被害人身處的無助情境，不能評價為強暴或脅迫的實行¹⁴⁹，但被害人的性自主意思顯然受到壓抑。有鑑於此，德國的立法者才會在1998年修法（第6次刑法修正案）時，於該國刑法第177條第1項（性強制罪）的強暴與脅迫之外，新增第三種行為模式（第3款）：利用被害人受行為人宰制的無助處境（*unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist*）。修法後，德國性強制罪所掌握的妨害自由手段，就要比強制罪來得更多¹⁵⁰。這種行為態樣亦屬違反被害人意願，只不過德國立法者是透過外在情狀來表達被害人意願被違背的事實，而非取決於被害人的主觀態度（意願）。對於該次的修法，有學者給予高度肯定，認為這是改善被害人保護的重要里程碑¹⁵¹，填補了像是【例5】的處罰漏洞。就此而言，前述主張透過「利用無助情境」來解釋概括條款的建議，在大方向上值得贊同。然而，「無助情境」這個概念相當抽象，德國性強制罪所新增的這個行為選項在該國學界也引發了不少爭論。例如，多數學者認為，如果只是被害人自己覺得無助（主觀上的無助），就還不足以肯定條文中的無助情境，而必須取決於客觀觀察者的角度¹⁵²；但另亦有文獻相反地主張，純粹主觀上的無助感亦可該當該款規定（也就是

149 *Friedrich Toepel*, in: *Kindhäuser/Neumann/Paeffgen* (Hrsg.), *Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 3. Aufl., 2010, § 240 Rn. 33.

150 *Maurach/Schroeder/Maiwald* (Fn. 37), 18/9. 我國法中其實也有類似的描述，像是在人口販運防制法第31條第1項、第32條第2項以及第34條第2項的構成要件中，均有「利用他人不能、不知或難以求助之處境」這個要素。

151 見 *Hörnle* (Fn. 28), § 177 Rn. 93.

152 如 *Hörnle* (Fn. 28), § 177 Rn. 104; *Kindhäuser* (Fn. 72), § 177 Rn. 4; *Fischer* (Fn. 28), § 177 Rn. 28; *Gössel* (Fn. 28), 2/35 f.; *Laubenthal* (Fn. 2), Rn. 208。也有德國學者建議應修法將利用無助情境改為「在顯然欠缺同意的情形下」，以杜絕純粹主觀理解的可能及弊病（如 *Hörnle* (Fn. 55), S. 326.）。但如此又會引發其他的新問題，像是行為人的故意是否亦須及於欠缺同意的「明顯性」？對此可參見 *Isfen* (Fn. 10), S. 229 f. 的分析。

所謂的被害人觀點)¹⁵³。除此之外，應如何理解無助情境與乘機性交罪中「無抵抗能力」二者間的關係，也引發了不少爭論¹⁵⁴。因此，在德國學界亦有學者將之評價成失敗的修法¹⁵⁵。由此可知，若是要參考德國法上「利用無助情境」的概念，恐怕還必須再做相當程度的補充或修正，否則就只是複製德國學界的爭議轉貼到我國而已。

(二) 不能抗拒或難以抗拒的方法？

如前所述，即便在修法後，也還是有學者建議仍應以「至使不能抗拒」或「足使難以抗拒」為本罪的要件，也就是主張將概括條款理解成「其他足以至使不能抗拒（或難以抗拒）的方法」，希望把現行法還原成1999年修法前的樣貌¹⁵⁶。法律適用者透過解釋直接推翻立法者明白表示的修法理由，雖然罕見，但只要結論沒有超脫法條的文義範圍，便仍在容許的界限內。不過若是要採取此種立場，就必須面對另一個難解的技術性問題：如何認定被害人業已「不能抗拒」或「難以抗拒」？如果在這裡一直繞著被害人的具體心理狀態打轉，恐怕最後只會淪為恣意決斷、各說各話的局面，因為「不能抗拒」、「無法抗拒」或「難以抗拒」這些概念並沒有清楚固定的語意內涵。儘管我們在口語中經常使用這些語詞（像是流行的廣告詞：無法抗拒的誘惑），所要表達的大致上就是「很難拒絕」的心理狀態。然而，從日常生活經驗可知，讓自己難以拒絕對

153 如Perron/Eisele (Fn. 30), § 177 Rn. 9; Renzikowski (Fn. 27), § 177 Rn. 40。甚至還有主張應包括被害人對於客觀上那些與防衛可能性相關的事實評估錯誤的情形，如Frommel (Fn. 28), § 177 Rn. 51。

154 對此，可參閱Joachim Renzikowski, Das Sexualstrafrecht nach dem 6. Strafrechtsreformgesetz—I. Teil, NStZ 1999, S. 377 (379 ff.) 的整理。

155 如Gössel (Fn. 28), 2/35; Laubenthal (Fn. 2), Rn. 200; Eschelbach (Fn. 10), § 177 Rn. 21。

156 但也有學者嚴厲斥責這種作法，像是陳昭如（註5），頁219：儘管「至使不能抗拒」要素已被刪除，卻仍陰魂不散地被實務界拿來當作違反意願的認定標準，成為一種「幽靈構成要件」。

方要求的可能因子有無限多，有時甚至只是基於金錢或人情的因素。

同樣的問題，也會出現在現行刑法第328條第1項（強盜取財罪），因為該條項仍保有「至使不能抗拒」這個要素。在強盜罪的脈絡下，學說上雖然對於該要素的認定又進一步提出了客觀基準（平均一般人）、主觀基準（被害人）以及折衷說等認定建議，但遇到具體個案時，無論透過何種判準，恐怕都很難得出清楚一致的答案。舉例來說，同樣是持水果刀行搶，最高法院在一則被告手持水果刀抵向男性被害人背部的案件，肯定了不能抗拒要素的該當（最高法院72年度台上字第5029號刑事判決），但在另一則被告將水果刀架在女性被害人肩上的案件，卻又否定被害人業已不能抗拒（最高法院79年度台上字第5023號刑事判決）¹⁵⁷；兩相對照之下，清楚印證了此要素難以擔保法安定性的質疑，最後必然會淪為法官的恣意決斷。因此，本文也反對讓條文回復到修法前樣貌的解釋建議。

六、本文立場：利用既存的強制狀態

（一）與前導例示概念間的牽制關聯性

在進一步對概括條款提出本文的具體判準之前，首先要提醒的是，如果我們對於例示概念做了限縮解釋（像是脅迫的內容限於針對生命或身體的重大影響），那麼當具體案件中的脅迫行為不該當這樣的限縮時（例如，行為人是以名譽或財產上的不利益作為惡害內容），自然就不能再透過概括條款「敗部復活」，否則將會使得先前的限縮完全失去意義。更重要的是，從選擇自由的角度來看，這些情形中的性交決定都是自主作成，並無違反意願可言。

¹⁵⁷ 對此，可參閱陳子平（註64），頁455-460對於學說與實務意見的整理，以及蔡聖偉，論強盜罪「至使不能抗拒」之認定，月旦裁判時報，24期，頁131以下（2013年）的分析。

如前文伍、五、(一)所述，我國立法者透過前導例示概念，業已窮舉了強制罪構成要件中所列出的全部強制手段（強暴與脅迫），因此在解釋「其他方法」時，就只能著眼於這些強制行為態樣以外的方式。但在另一方面，概括條款與前導例示概念均屬引發同一法律效果的構成要件選擇要素（Tatbestandsalternativen），立法者透過形式同等位階（gleichrangig）的方式串連，藉此也同時宣示了各個選擇要素在不法內涵上的等價性¹⁵⁸。因此，法律適用者在解釋概括條款時，必須參酌前導例示概念在大方向上的指引（性自主受到壓抑、性行為的選擇自由被剝奪），才能維持選擇要素之間的等價性。一個能夠同時滿足這些要求的解釋，就是將概括條款的適用限於「行為人利用行為時業已存在的強制狀態」。所謂的強制狀態（Zwangslage），與前導例示概念相對應，包括了物理和心理兩方面。而此處所稱的「利用」（Ausnutzung），則係指性接觸正是透過該種特殊強制狀態所促成（或是至少變得更容易）¹⁵⁹。由於這些影響意思自由的因素在行為前便已存在，行為人自然沒有再為任何強制行為的必要，像是前文所舉的【例5】。國內有文獻指出，強制性交罪為複行為犯（mehraktige Delikte），如果行為人沒有實施強暴或脅迫，被害人因為擔心抗拒會招來暴力攻擊，故而順從對方的性交要求，便不構成本罪¹⁶⁰。若果如此，那麼像是在【例5】的情形，就存在著一個亟需填補的處罰漏洞，因為這裡的被害人其實已

158 關於構成要件選擇要素這種立法模式，可參閱Sheng-Wei Tsai, Zur Problematik der Tatbestandsalternativen im Strafrecht-Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom strafrechtlichen Tatbestandsmerkmal, 2006, S. 25 ff., 27 ff. 的分析。

159 此定義參考自Wolters/Horn (Fn. 40), § 177 Rn. 13c對該國性強制罪中「利用無助情境」模式的解釋。其也同時強調，行為人主觀上必須對此亦有所認知才稱得上是「利用」。不過，行為人主觀上對於相關事實是否有認知，是主觀構成要件（故意）的問題，在審查客觀構成要件該當性時，則僅須（應）考慮客觀事實。

160 見甘添貴（註3），頁236。類似說法已見最高法院22年上字第477號刑事判例：「強姦罪之成立，於姦淫行為外，尚須有行強之行為，苟犯人於求姦之際，尚無行強情形，僅因被姦者自己之疑慮，恐其將至行強，為避免行強之發生，而認許姦淫者，則仍為和姦而非強姦」。

經沒有選擇空間，其性自主意思無疑受到強大的壓迫。然而，就如上文伍、五、所述，從構成要件的文字即可直接看出，強制性交罪的適用範圍並不限於施行強暴或脅迫的情形。倘若我們將本罪的概括條款理解成行為人利用既存的強制狀態來遂行性交目的，強制性交罪就不必然是複行為犯¹⁶¹，便可在不修法的情形下，消弭這個處罰漏洞，透過強制性交罪來制裁【例5】的行為人。

由於前導例示概念與概括條款二者相互牽制，因此這裡所謂「既存的強制狀態」，在強制程度上就必須和前導例示概念的強制效果（在物理上或心理上剝奪選擇可能性）相當¹⁶²，才能維持選擇要素之間的不法等價性，也才能合乎本文在前面所證立的「違反意願」內涵：喪失選擇自由¹⁶³。一個簡易的快篩判斷方式，就是先假設該強制狀態是行為人基於違犯本罪之故意所創設，然後判斷是否會該當前導例示概念；答案若為肯定，行為人便該當此概括條款，成立強制性交罪。以下，我們就分別針對心理上的強制狀態與物理上的強制狀態進一步說明。

¹⁶¹ 德國刑法第177條第1項的性強制罪加入利用無助情境的模式後，也引發了類似的討論。多數文獻認為修法後該罪便不必然要實施兩個各別獨立的行為（僅參閱Frommel (Fn. 28), § 177 Rn. 28.），這也是德國實務界的看法（如BGHSt 45, 257 ff.; BGH NStZ 2004, 440）。但亦有文獻堅持該罪的複行為犯性質（如Fischer (Fn. 28), § 177 Rn. 36a ff.; Eschelbach (Fn. 10), § 177 Rn. 33 ff.; Laubenthal (Fn. 2), Rn. 200.）。事實上，性行為的施行當然可以同時體現為一種利用行為，隨而就沒有複數構成要件行為可言。

¹⁶² 舊法時期，最高法院就已經有判決在解釋條文中的「他法」時強調此點，像是最高法院87年度台上字第406號刑事判決：強姦手段中所謂「他法」，乃所列舉之強暴、脅迫、藥劑、催眠術以外之補充概括規定，必其所用方法，有使婦女畏懼，致顯難（不能）抗拒或使其喪失意思自由而不知（不能）抗拒，始克相當。

¹⁶³ 詳請參閱前文參、以及肆、二、（一）的說明。要注意的是，在強盜罪（刑法第328條第1項）的構成要件行為中，立法者同樣於強暴與脅迫之外列有「他法」，但由於該罪另要求這些手段必須「至使（相對人）不能抗拒」，利用既存強制狀態似乎難以符合此要求。

(二) 利用既存的心理強制狀態

在前面所舉的【例5】中，行為人就是利用了既存的心理強制狀態。要注意的是，我們在前文肆、二、(一)提過，本罪脅迫選項的惡害內容應限於對生命或身體的現時危險，否則就稱不上違反被害人的意願。基於相同的道理，在概括條款這裡，被利用的強制狀態也應該限於被害人在心理上擔憂自己生命或身體上的安全；像是身處在一個充斥暴力氛圍（Klima der Gewalt）的環境中，擔心反抗會招致對方的暴力攻擊。由於此時被害人所面臨的選項是「忍受性交」及「在被攻擊後忍受性交」，就其是否從事（或忍受）性交這部分，被害人其實並沒有選擇的空間（主觀上失去選擇自由），所做出的忍受決定自然就不能解讀成有接受性交的自主意願。反之，如果被害人只是擔心對方會跟自己分手，或是怕丟掉工作，對於是否從事性交乙點自然就還有選擇的空間，所做出的性交決定即屬自主做成，便不會落入本罪的概括條款中。

被害人對於潛在攻擊行為的畏懼，可以參考德國學界對於該國性強制罪中「無助情境」要素的解釋。被害人的恐懼，通常來自於物理上的劣勢地位（die physische Unterlegenheit）。此處的認定，須斟酌整體情狀綜合評估，特別要考慮當事人的年齡、身心狀況、社會地位¹⁶⁴、行為地的周遭環境（附近是否有任何可期待會伸出援手的第三人¹⁶⁵），以及被害人當下受到的刺激（是否因過度驚嚇而僵硬呆滯無法及時反應¹⁶⁶）等。原則上，行為人在體型、體力上的優勢越明顯，被害人的抵抗就越顯得沒有意義，行為人也就越不需要施展力量即能達成目的¹⁶⁷。此時被害人的反抗不但毫無希望，還可

¹⁶⁴ 參閱Theo Ziegler, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Strafgesetzbuch (Beck'scher Online Kommentar), 2012, § 177 Rn. 20.

¹⁶⁵ 此見Maurach/Schroeder/Maiwald (Fn. 37), 18/12.

¹⁶⁶ 德國立法者在立法理由中的說明，參考自Wolters/Horn (Fn. 40), § 177 Rn. 13a.

¹⁶⁷ Hörnle (Fn. 28), § 177 Rn. 96.

能招來進一步的攻擊，往往就會因為害怕對方施用暴力而放棄抵抗。在這種情形下，行為人雖然沒有實施強暴或脅迫的行為（亦無此必要），但被害人的主觀意願仍屬受到戕害。此外，這種心理上的強制狀態也有可能來自於長期透過暴力形塑的相處關係，特別是參與者必須朝夕共處的情形。居弱勢的一方雖然一開始曾表達過反對的意思，但卻因此招來強勢的他方暴力相向及蔑視，經過反覆施行後就形成了固定的行為模式，弱勢者久而久之便因反抗無望而不再表達反對¹⁶⁸。若依本文的主張，只要能夠證明弱勢的一方係處於心理上的強制，亦即其確實是因為擔憂自己的生命或身體安全而選擇忍受性交，便可適用本罪的概括條款。

純理論地分析，身處無助環境的被害人當然也有可能是在沒有任何畏懼的狀況下，自主決定與行為人從事性交行為。不過當行為人提出此種抗辯時，必須有客觀上的具體根據，法院不能只因為無法確切排除這種純粹臆想的抽象可能性，就援用罪疑唯輕原則否定本罪的成立¹⁶⁹。具體案件中的情況當然也可能相反，亦即客觀上雖然沒有無助的情境，但被害人因為主觀上有所畏懼而不敢拒絕行為人的要求。只不過，基於法安定性以及構成要件明確性的要求，不能讓成罪與否全然取決於被害人單方面的主張，故於此同樣必須要有具體的客觀事實根據來支持、佐證¹⁷⁰。

最後還要再說明的是，行為人所利用的強制狀態，亦包括被害人因為與行為人無關的事實陷入心理上癱瘓的情形。就性自主的侵害來說，強制情境的形成是否可歸咎於行為人，並不會對於被害人在

168 此種類型參考自Hörnle (Fn. 55), S. 325。但因為這種情形在客觀上無法辨識，Hörnle教授便主張，應將主觀要件的成罪門檻設定在行為人明知（直接故意）的情形，見Hörnle (Fn. 55), S. 326 f.

169 因為罪疑唯輕原則的適用前提是「有根據的懷疑」，而非單純想像上的抽象可能性；詳見蔡聖偉，刑法問題研究（一），頁30以下（2008年）。

170 德國通說在解釋該國刑法中的「無助情境」時，亦持此種客觀認定的態度，見前註152。

這種情境下被迫接受性行為所達成的侵害強弱有所影響；換句話說，並不會因為行為人與強制情境的形成無關，被害人的傷害就會少一些。不過，既然利用被害人的畏懼成為構成要件要素，那麼行為人主觀上的故意自然也必須對此有所認知。倘若行為人完全沒有注意到被害人的畏懼（心理層面的癱瘓），誤以為對方不反抗是出於合意，便會形成阻卻故意的構成要件錯誤。

（三）利用既存的物理強制狀態

依照本文看法，概括條款所掌握的強制類型，不限於心理層面，亦包括物理上的強制狀態，這也是本文主張與德國立法及通說的最大不同處。在這種情形，行為人在物理上已無法動彈，自然更加沒有自主決定可言（客觀上失去選擇自由），像是：

【例6】被害人甲在郊外遭案外人洗劫財物，被綑綁而動彈不得，與該案外人無關的乙偶然經過，見狀後臨時起意，想利用甲無法動彈反抗的狀態與之性交，便不顧甲明白表示的反對意思而對之施行性交行為。

國內多數學者認為強制性交罪係屬複行為犯，本例中的強制狀態乃透過無關的第三人所造成，行為人既然沒有（自己或透過其他共犯）對被害人施以強制行為，自不該當本罪，而應成立乘機性交罪¹⁷¹。與此相對，也有部分文獻認為此處應成立強制性交罪¹⁷²。

171 如韓忠謨（註9），頁262；陳樸生（註9），頁613；甘添貴（註3），頁263；陳煥生、劉秉鈞，刑法分則實用，4版，頁262（2013年）；林東茂，乘機性交與詐術性交，月旦法學教室，60期，頁79（2007年）；王皇玉，引狼入室（註89），頁27。實務見解亦同，參見法務部檢察司法（75）檢二字第1013號函之14，以及最高法院71年台上字第1562號刑事判例。德國學界與日本學界的通說亦同此結論，參閱Otto (Fn. 27), 66/23; Hörnle (Fn. 28), § 179 Rn. 25; Ziegler (Fn. 164), § 179 Rn. 10; Gössel (Fn. 28), 3/14；西田典之著，王昭武、劉明祥譯（註133），頁112；山口 厚著，王昭武譯（註133），頁125。

172 如黃榮堅，刑罰的極限，頁294-295（1999年）；盧映潔（註13），頁391-392（被害人並非處於無法或難以擷取其意向的狀態）；李聖傑，從性自主權思考

其中最重要的理由就是：無論最後實行性交行為的人是否為原本實施強制行為的那個人，對於被害人所造成的痛苦和侵害都一樣¹⁷³。依照本文對於概括條款所提出的判準，少數說的結論即屬當然。行為人若是利用了既存的絕對強暴狀態來完成性交行為，只要被害人於行為時仍有意識並且也表明了反對的意向，便應成立強制性交罪。這也適用於行為人基於他罪故意造成此種強制狀態的情形，像是：

【例7】甲基於單純妨害行動自由的故意，將乙制服並綑綁，要離去之際竟又起了色心，便利用乙無法動彈反抗的狀態，不顧其明白表示的反對意思而對之施行性交行為。

通說認為，複行為犯的各個構成要件行為之間必須存有特殊的主觀聯結，因此，強制性交故意必須在行為人從事第一個構成要件行為時即已存在¹⁷⁴。由於本例中行為人於施用強暴行為（綑綁）排除被害人的意思實現能力時，尚未形成性交的意念，故無法就此動作成立強制性交罪。嗣後另行起意利用強制狀態遂行性交目的時，由於強暴行為業已完成，亦無需再為任何強制手段，因此至多只能適用乘機性交罪¹⁷⁵。但若拿這種情形與一般出於性交目的施加強暴

刑法的性行為，中原財經法學，10期，頁19以下，21-22（2003年）；廖宜寧（註133），頁160-161。德國學界採此看法者，則如Frommel (Fn. 28), § 179 Rn. 26（亦成立性強制罪中的利用無助情境類型）；Maurach/Schroeder/Maiwald (Fn. 37), 18/10.

173 此見黃榮堅（註172），頁294-295。德國學界亦有類似說法，如Hörnle (Fn. 10), S. 208 f.。依其看法，性自主決定權的侵害並非在於對被害人意思形成的影響，而是在於「行為人從事了未經被害人允許的性行為」，所以應該放棄複行為犯的結構設計，參見Hörnle (Fn. 55), S. 315.

174 僅參閱Detlev Sternberg-Lieben/Irene Sternberg-Lieben, Vorsatz im Strafrecht, JuS 2012, S. 976 (980)的整理說明。國內文獻則多半是在強盜罪的脈絡下討論，如林山田（註57），頁379-380；陳子平（註64），頁462；陳志龍，人性尊嚴與刑法體系入門，5版，頁358-359（1998年）；黃惠婷（註37），頁18。

175 採此結論者，如甘添貴（註3），頁238-239。德國學界多數說亦同，僅參閱Jörg Eisele, in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., 2014, § 179 Rn. 10; Gereon Wolters, in: Satzger/Schmitt/Widmaier (Hrsg.),

行為的情形相較，差別只在於行為人主觀上的意思狀態。對被害人來說，行為人性交意念出現的早晚並不會有任何不同，總之都是在違背意願（欠缺決定是否接受性交的選擇自由）的情形下被迫接受性行為，依照本文看法亦應成立強制性交罪。

不過要注意的是，違反意願這個概念，應以被害人對於行為人的性交要求有所認知並且也形成了反對意思（*der entgegenstehende Wille*）為前提。依此，概括條款中行為人所利用的既存強制狀態，就不包含被害人業已失去意識的情形。如前所述，絕對強暴的概念中，也包含讓對方無法形成意志（例如被麻醉）的類型。被害人因飲酒或服藥而陷入無法形成意志的酩酊狀態，雖然也是一種既存的物理強制，但行為人利用此種狀態遂行性交目的（俗稱的「撿屍」行為）所侵害的是被害人的性自主決定（是否要和該名行為人於該時空以該種方式發生性關係的決定權），而未壓制被害人的具體意思決定（因為當下並無任何具體的反對意思），故不該當強制性交罪，僅成立乘機性交罪¹⁷⁶。

於此還要附帶說明的是，如果是行為人自己製造出被害人失去意識的狀態（例如暗中下藥），並利用此種狀態遂行性交目的，學界與實務界均無異議地認為應成立強制性交罪。本文亦贊同此結論。於此種情形，行為人實行性交行為的當下，被害人亦無實際的反對意思可言；之所以仍然成立強制性交罪，是加入了規範性的評價。詳言之，因為行為人是故意製造並有意利用被害人失去意識的狀態來遂行性交目的，而使人喪失意識的行為剝奪了對方形成意思

Strafgesetzbuch Kommentar, 2009, § 177 Rn. 26。要注意的是，我國刑法第225條第1項所規定的文字（精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形）與德國刑法第179條第1項第2款（身體上無能力抵抗）有異，故在本例中，被害人的情形是否可該當前者的概括條款，似乎還有討論的空間。但此已屬乘機性交罪的解釋問題，也牽涉到該條文字在修法過程中的修改理由，是一個必須獨立處理的議題，於此便不再繼續探究。

¹⁷⁶ 德國通說亦同此結論，僅參閱Hörnle (Fn. 28), § 177 Rn. 55.

決定的可能，所以在規範評價上，應該等同於行為人基於強制性交之目的將反抗的被害人打昏的情形，均屬違反被害人的意願，才能充分評價所有的不法事實。不過，這樣的處理方式並非邏輯上所必然；像是在日本刑法典中，使人失去意識以遂行性交意圖的行為便不是構成強姦罪¹⁷⁷，而是透過該法中的準強姦罪來掌握¹⁷⁸。

（四）與「乘機性交罪」的關係

如果對於概括條款採取本文的解釋建議，接著可能會浮現的問題就是，如此是否會讓本罪與乘機性交罪（刑法第225條第1項）兩罪名難以區分？依照國內通說，強制性交罪與乘機性交罪二者係處於一種「屬此必非彼」的排他互斥關係，透過「被害人欠缺抵抗能力的狀態是既存事實還是由行為人所製造」乙點，將二罪名切分開來¹⁷⁹。對此首先要說明的是，其實我們根本不需要（也不應該）把強制性交罪與乘機性交罪理解成排他互斥¹⁸⁰，而是仍有形成競合的可能。多數德國學者認為，對於所有利用被害人「無抵抗能力」（Widerstandsunfähigkeit）的狀態來遂行性交意圖的情形來說，乘機

¹⁷⁷ 日本刑法第177條（強姦罪）規定：以強暴或脅迫姦淫13歲以上之女子，為強姦罪，處3年以上有期徒刑。姦淫未滿13歲之女子者，亦同。

¹⁷⁸ 亦即該當日本刑法第178條第2項後段：使女子心神喪失或不能抗拒而為姦淫行為，依前條（強姦罪）之例處斷。完整的條文內容，參見前註133。若將本項規定與該法第177條兩相對照，便可看出日本刑法的立法者採取了較狹隘的強暴概念，而與我國的舊法思維相同，見前註33。

¹⁷⁹ 僅參閱林山田（註57），頁243-244；林東茂（註71），頁2-79。我國實務界亦同（最高法院71年台上字第1562號刑事判例：如被害人不能抗拒之原因，為犯人所故意造成者，應成立強姦罪或強制猥褻罪。如被害人不能抗拒之原因，非出於犯人所為，且無共犯關係之情形，僅於被害人心神喪失或其他相類之情形不能抗拒時，犯人乘此時機以行姦淫或猥褻行為者，則應依乘機姦淫或乘機猥褻罪論處）。德國部分文獻亦將性強制罪與乘機性交罪二者理解成排他互斥，如Fischer (Fn. 28), § 177 Rn. 30; Gössel (Fn. 28), 3/38.

¹⁸⁰ 將二罪名理解成排他互斥，在事實不明、錯誤以及參與逾越的情形，會產生蘊含評價矛盾的處罰漏洞或是評價不足的問題，詳參閱蔡聖偉（註66），頁40以下的說明。

性交罪扮演了截堵構成要件（*Auffangtatbestand*）的角色¹⁸¹。這句話在大方向上可予贊同，但在細節上則未盡周延而需修正。因為無論是依照我國法還是德國法，乘機性交罪的構成要件對於無抵抗能力的形成原因均設有限制，實現強制性交罪的事實未必也會同時該當這些特定原因，所以只有在部分情況才會形成競合的局面。像是在行為人以絕對強暴的方法剝奪被害人的行為能力（例如使用藥劑令其昏迷）進而遂行性交意圖的情形，行為人除了構成強制性交罪之外，亦同時成立乘機性交罪¹⁸²。因為從整個行為過程的後半段來看，行為人的確是利用被害人在物理上無能力抵抗的身體障礙狀態來完成性交，亦該當刑法第225條第1項「利用他人不能抗拒而為性交」的要件。只不過為了避免重複評價，適用強制性交罪即足以完整評價整體犯行的不法內涵，排除了乘機性交罪的適用，二罪名係處於不真正競合的關係¹⁸³。基此，行為人一旦同時構成這兩個罪名，乘機性交罪在競合時便會被排擠而不適用。所以一般所謂兩罪名間的區隔界分問題，精確地說，應該要轉換成：實現乘機性交罪的行為何時不會同時成立強制性交罪¹⁸⁴？

倘若被害人於性交時已表示同意，即便該同意是因其處在行為控制力顯著低下的狀態（如躁鬱症患者）或是知覺能力較低（如智

181 僅參閱Lackner/Kühl (Fn. 28), § 179 Rn. 1，這種看法也是德國實務界的立場，見BGH NStZ 2000, 140。但有少數學者持不同意見，認為現行德國刑法中的乘機性交罪在1997年修法後便脫離截堵構成要件的補充地位，而具有獨自的不法內涵，如Frommel (Fn. 28), § 177 Rn. 95。

182 Eisele (Fn. 175), § 179 Rn. 10。

183 同此見解者，如Renzikowski (Fn. 27), § 179 Rn. 66; Lackner/Kühl (Fn. 28), § 179 Rn. 14; Otto (Fn. 27), 66/21。國內文獻中，亦有主張乘機性交罪與強制性交罪係處於法條競合中的補充關係，如甘添貴（註3），頁262。主張乘機性交罪具有獨自的不法內涵者，於此則會認定成想像競合，如Frommel (Fn. 28), § 177 Rn. 95。

184 這在涉及到基本構成要件與變體構成要件的特別關係時，可以看得最清楚，所以不會有人提出像是「應如何區分普通竊盜罪與加重竊盜罪」這樣的問題。強制性交罪與乘機性交罪二者間雖然沒有邏輯上的特別關係，但背後道理類似。

能障礙者)¹⁸⁵，依照學說看法，都會在強制性交罪這裡形成阻卻構成要件該當性的效果，至多只成立乘機性交罪等他罪名。而在被害人於性交時已無知覺意識的情形（如昏迷、酩酊或熟睡），除非該無意識的狀態是行為人基於性交目的所招致，否則亦和強制性交罪無關。只有在被害人於性交時仍具意識，並且表示反對接受性交，但因物理障礙而無法抗拒行為人的情形（如【例6】與【例7】），若採本文的解釋建議，才會在乘機性交罪之外，另成立強制性交罪（利用既存的強制狀態），後者排除了前者的適用。這樣的結論雖然異於通說，但有其事理上的依據，我們已經在前文伍、六、（三）討論過。而這樣的結論，也可以從侵害法益的面向來說明。乘機性交罪的不法核心雖然也在於性自主決定權¹⁸⁶，也就是在性的範疇不受他主決定的自由¹⁸⁷，但強制性交罪還更進一步地保護被害人對於具體性交行為的實際意願（行為時的具體自由意思）¹⁸⁸。若我們在【例6】和【例7】中僅論以乘機性交罪，將無法宣示行為人罔顧被害人反對意思這部分的不法。同樣的道理，利用肢體障礙人士無法反抗而遂行性交目的，依照前述通說的區分判準，由於被害人係屬不能抗拒，而此種欠缺抵抗能力的狀態並非行為人所製造，所以也只成立乘機性交罪。然而，被害人於行為當下若仍具有意識，並且

185 許玉秀（註7），頁32。要注意的是，如果不區分情形，舉凡性行為的對象為本罪所列之人，就一網打盡全部成罪，將會使得本罪成為精障者或患有心理疾病者的性行為禁令（見Hörnle (Fn. 28), § 179 Rn. 55.）。因此，本罪的適用，應該限縮在行為人把被害人當成滿足自己性需求的純粹工具客體的情形（參閱Laubenthal (Fn. 2), Rn. 326.）。

186 僅參閱Hörnle (Fn. 28), § 179 Rn. 2.

187 此見Laubenthal (Fn. 2), Rn. 300。亦即，若是將這些導致不能抗拒的原因除去，被害人便有可能會拒絕該性交行為（Wolters/Horn (Fn. 40), § 179 Rn. 5.）。要注意的是，此處的重點僅在於被害人反對的「可能性」，至於被害人是否真的會反對該乘機實行的性交行為，則非重點。

188 因此有文獻指出，乘機性交罪的行為非價既然較強制性交罪為輕，立法者賦予二者相同的法定刑即有違罪刑均衡原則，參見陳子平（註64），頁245。不過成立強制性交罪便有適用刑法第222條加重規定的可能，就此而言，還是具有較乘機性交罪更重的處罰可能性。

也表明了反對性交的意思，就應該成立強制性交罪¹⁸⁹，如此才能充分評價整體犯行的不法內涵。

綜上，行為人實行性交行為時，只要被害人仍有意識並且也表達了反對的意思，即便其已失去物理或心理上的抵抗能力，仍應成立強制性交罪，透過競合規則排擠同時成立的乘機性交罪¹⁹⁰。反之，被害人於性交行為時若已失去意識（例如被灌醉），而該無意識狀態亦非行為人基於性交目的故意造成，便不會該當強制性交罪的構成要件，僅成立乘機性交罪。

陸、結語

1999年關於性犯罪的修法，在增訂強制性交罪違反意願要素的部分，究竟應該評價成一段黑暗的刑法史，還是超越其他國家的先進立法，端視我們能否對於這個概括條款找到一個既能填補處罰漏洞又能擔保安定性，並且合乎事理的判準，這也是本文的主要任務。以下，便將本文的主要論點依序分項列出：

（1）「違反被害人意願」這個要素，是本罪構成要件行為模式的概括條款，也同時是所有前導例示概念（強暴、脅迫、恐嚇與催眠術）都必須具備的共通性質。

（2）在本罪的脈絡下，被害人的「意願」應係指其關於是否從

189 同此結論者，如黃榮堅（註4），頁1837註108。此結論亦可從刑法第222條第1項第3款的加重事由（對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人違犯）得到印證。

190 但也有學者主張，即便被害人基於不可歸咎行為人的原因陷於昏迷，亦應成立強制性交罪，如黃榮堅（註172），頁294-295。若依此看法，則乘機性交罪的適用範圍就會更狹隘，限於被害人因為「不可歸責於他人」的因素陷入無抵抗能力的狀態（例如自己喝酒醉倒）。

事（或忍受）性交的選擇。依此，所謂「違反意願」就是指被害人的相關選擇自由空間被剝奪。反之，如果被害人的性交決定可被評價為自我選擇的結果，該決定即屬自主做成，便無違反其意願可言。

（3）強暴行為的部分，重點在於對被害人身體上直接形成的物理作用力，解釋上應限於對人強暴的類型，而不包括對物強暴。

（4）脅迫行為的部分，應該要對惡害的內容加以限縮，限於以生命或身體的現時危險作為脅迫內容（而非包括一切的不利後果），這樣才會剝奪被害人關於是否接受性行為的選擇自由，才稱得上是違反其意願。

（5）概括條款「其他違反被害人意願之方法」在解釋上必須受到前導例式概念（強暴與脅迫）所拘束，亦即應具有剝奪被害人選擇自由的性質。但法條中所羅列的「強暴、脅迫、恐嚇、催眠術」這些前導例示概念已經窮舉了強制罪的所有強制手段，隨而在解釋「其他方法」時，就只能從強制手段以外的行為模式著眼。

（6）應將概括條款理解成行為人「利用既存的強制狀態遂行其性交目的」的情形，行為人利用此種狀態來遂行性交目的，本質上與透過強制行為迫使被害人接受性交要求的不法內涵相當，均屬違反被害人意願。此處所稱的強制狀態，可分成心理及物理兩個面向。

（7）典型的心理強制狀態，就是被害人業已身處聽任行為人宰制的無助處境中（例如被挾持監控），此時行為人自然沒有進一步實施強制（強暴或脅迫）手段的必要。由於被害人心理上擔憂反抗會招致進一步的暴力攻擊，故而放棄抗拒（主觀上失去選擇自由），其性自主決定亦屬受到壓制。

（8）物理上的強制狀態，則係指被害人在物理上已無法抵抗

(客觀上失去選擇自由)，但仍能清楚表意，並且也表示反對的情形。倘若被害人業已失去意識，而無法形成具體的反對意志，便僅能成立乘機性交罪。

透過以上的解釋建議，本罪的概括條款便含有妨害自由（強制）的性質¹⁹¹；除了得以更加完整地掌握應罰的法益侵害類型，並高度擔保法安定性外，亦使本罪的適用在體系上與其他構成要件不會產生衝突，讓1999年對於刑法第221條第1項所做的修改——至少在違反意願的行為模式部分¹⁹²——負面影響降至最低。立法者於該次修法原本冀望透過「至使不能抗拒」要素的刪除，擴展強制性交罪的適用範圍，但卻又因為添加了「違反意願」要素，反而導致例示要素（脅迫）被限縮。若是認為在行為人透過其他惡害（如侵害第三人的生命、身體，或是侵害被害人的名譽或財產）相脅的情形僅論以強制罪會有過輕之虞，則應透過修法來校正¹⁹³。最大幅度的修改建議，就是放棄複行為犯的構成要件結構，然後將本罪的構成要件行為限定在「未經同意」的性交行為¹⁹⁴。如此除了更加凸顯出性侵害犯行的非難重點外，也可以透過本罪來掌握像是【例4】的行為¹⁹⁵。不過若要改採此種立法選項，就必須先審慎思考前文伍、

191 隨而使用「強制」性交罪的稱呼就不會有什麼問題。關於罪名稱謂的說明，另請參見前註3。如果在解釋上不要求概括條款須具強制性質（如前文伍、二、至四、所討論的立場，或是最高法院97年度第5次刑事庭決議），卻又將本罪稱作強制性交罪，便會有自我矛盾之嫌。

192 但是在性交行為部分的修法，則很難透過解釋找到圓滿的結局。因為在1999年的修法中，立法者一方面大幅擴張性交概念（刑法第10條第5項），另一方面卻仍保留強制猥褻罪，使得後一罪名被大幅架空。事實上，關於性犯罪的幾次修法都是重大案件所促成，修法前缺乏全面性的學理討論，修法後會漏洞百出自然也就不足為奇。

193 各種修法選項請見前文肆、二、（一）的介紹。

194 也就是改採「只有可以才行」的立法模式。另有學者建議，若要採此模式，最好避免使用「同意」一詞，改用「允許」（Zustimmung）來代替，以免被捲入刑法上關於同意概念的諸多爭議（見Hörnle (Fn. 28), Vor § 174 Rn. 52; Hörnle (Fn. 55), S. 326.）。

195 但要注意的是，即便在「只有不可以才不行」的立法模式下，亦可透過對於刑法第225條概括條款（其他相類之情形）的擴張解釋、修法（如仿照日本刑

三、所提到的諸問題（特別是作為行為指導規範的適宜性），並且要一併修改相關條文（像是刑法第225條）。歐洲理事會（Council of Europe）於2011年議定了《伊斯坦堡協定》（Istanbul Convention）¹⁹⁶，賦予簽署國將特定性侵犯行為犯罪化的義務，其中在性暴力的部分，相當強調性侵犯行為「未經同意」（non-consensual）的特性¹⁹⁷。該協定在德國刑法學界引發了一陣討論熱潮¹⁹⁸，德國聯邦議會也立刻在2015年1月間召開公聽會，邀請了7名鑑定人對於德國性刑法的修法必要性提供鑑定意見¹⁹⁹，讓相關構成要件再度被拿出來徹底檢驗²⁰⁰。這股討論熱潮雖然尚未登陸臺灣，但可預見必然會對我國性刑法日後的修改或解釋產生相當程度的影響，值得我們持續留意觀察。

法立法例，刪除該條欠缺抵抗能力的原因限制，見前註133），或是透過新增犯罪構成要件來制裁【例4】的行為人。

196 全名為「歐洲委員會預防及抗制對女性施暴及家暴協定」（Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence），已於2014年正式生效。

197 其中第36條為關於性暴力（sexual violence）的規範，第1、2項的內容如下：

1. 締約方應採取必要的立法或其他措施，以確保下列故意行為被入罪：a) 以任何身體部位或工具，未經同意（non-consensual）且具性意涵（sexual nature）地侵入他人陰道、肛門或口腔；b) 對他人實行其他未經同意且具性意涵的行為；c) 促使他人與第三人實行未經同意且具性意涵的行為。
2. 同意（consent）必須是在當時情狀下基於個人自由意志自願地（voluntarily）做成。

198 德國文獻上的主要意見，可參閱Isfen (Fn. 10), S. 217 ff., 222 ff. 的整理與分析。

199 關於鑑定意見的主要內容及出處，可參閱Isfen (Fn. 10), S. 217 ff. 的整理。

200 甚至有學者認為，應該根據現代觀念革命性地全面翻修整個性刑法罪章，連同刑度都要一併調校，而不能只是點狀的修改；此見Isfen (Fn. 10), S. 231.

參考文獻

1. 中文部分

- 山口 厚著，王昭武譯（2011），刑法各論，中國北京：中國人民大學出版社。[山口 厚（2010），刑法各論，2版，東京：有斐閣。]
- 王皇玉（2009），引狼入室，月旦法學教室，87期，頁26-27。
- （2013），強制手段與被害人受欺瞞的同意：以強制性交猥褻罪為中心，臺大法學論叢，42卷2期，頁381-431。
- （2013），強制罪之比較研究，軍法專刊，59卷5期，頁1-12。
- 王曉丹（2014），性暴力法制的歷史交織：一個性別批判的觀點，軍法專刊，60卷2期，頁21-40。
- 甘添貴（1990），刑法各論（上），臺北：五南。
- （2000），強制性交罪之評析與適用，收於：林山田編，刑法思潮之奔騰（韓忠謨教授紀念論文集），頁325-358，臺北：財團法人韓忠謨教授法學基金會。
- （2013），刑法各論（下），2版，臺北：三民。
- （2013），刑法各論（上），3版，臺北：三民。
- 西田典之著，王昭武、劉明祥譯（2012），日本刑法各論，臺北：元照。[西田典之（2010），刑法各論，5版，東京：弘文堂。]
- 吳耀宗（2000），犯罪與法之抗制（一），桃園：中央警察大學出版社。
- （2008），強制性交罪與利用權勢性交罪，月旦法學教室，63期，頁16-17。
- （2013），被害人受騙之承諾，月旦法學教室，126期，頁27-29。

呂有文（1987），刑法各論，2版，臺北：自版。

李佳玟（2010），違反罪刑法定的正義，台灣法學雜誌，160期，頁1-3。

李聖傑（2003），從性自主權思考刑法的性行為，中原財經法學，10期，頁1-39。

——（2004），妨害性自主：第三講，類型闡述，月旦法學教室，23期，頁99-106。

——（2010），刑法第二二二條第一項第一款「二人以上共同犯之」之適用思考，政大法學評論，115期，頁1-53。

周漾沂（2014），風險承擔作為阻卻不法事由，中研院法學期刊，14期，頁169-235。

林大為（2013），論詐術性交罪——兼論「宗教騙色」案件之認事用法問題，軍法專刊，59卷5期，頁108-137。

林山田（2001），刑法的革新，臺北：學林。

——（2005），刑法各罪論（上），5版，臺北：自版。

——（2008），刑法通論（上），10版，臺北：自版。

林志潔、金孟華（2010），美國女性主義法學發展與性侵害防制法之改革，月旦法學雜誌，182期，頁144-161。

——（2012），「合理」的懷疑？以女性主義法學觀點檢視性侵害審判之偏見，政大法學評論，127期，頁117-161。

林東茂（2007），乘機性交與詐術性交，月旦法學教室，60期，頁78-85。

——（2015），刑法綜覽，8版，臺北：一品。

前田雅英著，董璠輿譯（2000），日本刑法各論，臺北：五南。[前田雅英（1989），刑法各論講義，東京：東京大學出版會。]

柯耀程（2008），情人看招（糟）！，月旦法學教室，66期，頁18-19。

徐育安（2012），故意認定之理論與實務，中研院法學期刊，10期，頁81-159。

- 徐偉群(2011)，需要翻轉的不是法律，是法界的知識狀態——強制性交罪修法應該停止，台灣法學雜誌，175期，頁1-3。
- 高金桂(2011)，強制性交罪的強制力行使——高雄地方法院九十九年度訴字第四二二號判決評析，月旦法學雜誌，189期，頁251-262。
- 涂春金、劉柏江(2012)，以宗教之名行騙性交是否構成強制性交罪？——兼論臺灣高等法院臺南分院99年度重上更(二)字第78號刑事判決暨最高法院99年度臺上字第8139號刑事判決，軍法專刊，58卷3期，頁50-64。
- 張天一(2013)，拿人錢財，不與人消災？——「類宗教行為」於詐欺罪上之問題／最高院100台上5493判決，台灣法學雜誌，234期，頁179-186。
- 梁恆昌(1986)，刑法各論，11版，臺北：自版。
- 許玉秀(1999)，刑法的問題與對策，臺北：自版。
- (2003)，妨害性自主之強制、乘機與利用權勢——何謂性自主？，台灣本土法學雜誌，42期，頁16-36。
- (2012)，重新學習性自主——勇敢面對問題，月旦法學雜誌，200期，頁302-323。
- 許恒達(2013)，乘機襲胸案刑責再考——評台灣高等法院台中分院102年度侵上訴字第47號判決，台灣法學雜誌，233期，頁150-161。
- 許澤天(2011)，面臨合法惡害威脅下的性自主，台灣法學雜誌，181期，頁120-125。
- 陳子平(2013)，刑法各論(上)，臺北：元照。
- (2015)，強盜罪與恐嚇取財罪之界限，月旦裁判時報，31期，頁31-39。
- 陳志龍(1998)，人性尊嚴與刑法體系入門，5版，臺北：自版。
- (2001)，酒不罪人，人自罪——妨害性自主罪之探論，月旦法學雜誌，75期，頁12-13。

陳昭如（2013），基進女性主義的強暴論，思想，23期，頁207-233。

陳煥生、劉秉鈞（2013），刑法分則實用，4版，臺北：一品。

陳樸生（1993），實用刑法，再版，臺北：三民。

彭國能（2013），刑法分則釋義精解，臺北：翰蘆。

曾淑瑜（2000），刑法分則問題研析（二），臺北：翰蘆。

黃東熊（1998），刑法概要，臺北：三民。

黃茂榮（2006），法學方法與現代民法，5版，臺北：自版。

黃惠婷（2005），刑法上的強盜罪，桃園：中央警察大學出版社。

——（2010），證明「違反意願」非強制性交罪之必要條件——簡評九九年度台上字第四八九四號判決與九九年刑事庭第七次會議決議，台灣法學雜誌，161期，頁195-203。

——（2011），刑法案例研習（三），臺北：新學林。

黃榮堅（1995），刑法問題與利益思考，臺北：元照。

——（1999），刑罰的極限，臺北：元照。

——（2011），2010年刑事法發展回顧：慾望年代，慾望刑法？，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1795-1841。

廖宜寧（2014），乘機性交猥褻罪的規範適用問題——以精神障礙者之性自主權利為中心，臺北：元照。

褚劍鴻（1991），刑事法學論著，臺北：自版。

——（2004），刑法分則釋論（上冊），4版，臺北：商務。

蔡聖偉（2008），刑法問題研究（一），臺北：元照。

——（2013），刑法問題研究（二），臺北：元照。

——（2013），論強盜罪「至使不能抗拒」之認定，月旦裁判時報，24期，頁130-133。

蔡墩銘（2006），刑法各論，5版，臺北：三民。

鄭逸哲（2010），與未滿16歲人進行性接觸之刑法適用，法令月刊，61卷12期，頁35-48。

盧映潔（2010），「意不意願」很重要嗎？評高雄地方法院九十九年

訴字第四二二號判決暨最高法院九十九年第七次刑庭決議，月旦法學雜誌，186期，頁164-173。

——（2015），刑法分則新論，10版，臺北：新學林。

錢建榮（2011），重點在於有無違反意願的「方法」——為恐龍法官喊冤，台灣法學雜誌，174期，頁1-4。

薛智仁（2000），強制性交罪（刑法第二二一條第一項）修正之研究，刑事法雜誌，44卷1期，頁84-113。

韓忠謨（1982），刑法各論，7版，臺北：自版。

2. 外文部分

Amelung, Knut (1999), Über Freiheit und Freiwilligkeit auf der Opferseite der Strafnorm, GA, S. 182-203.

Arzt, Gunther/Weber, Ulrich/Heinrich, Bernd/Hilgendorf, Eric (2009), Strafrecht, Besonderer Teil, Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Giesecking.

Baumann, Jürgen/Weber, Ulrich/Mitsch, Wolfgang (2003), Strafrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl., Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Giesecking.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1991), Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt: Suhrkamp.

Eisele, Jörg (2014), in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., München: C. H. Beck, § 179.

Eschelbach, Ralf (2013), in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, München: Vahlen, § 177.

Eser, Albin/Eisele, Jörg (2014), in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., München: C. H. Beck, § 240.

Fischer, Thomas (2000), Sexuelle Selbstbestimmung in schutzloser Lage, ZStW 112, S. 75-105.

- (2015), *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*, 62. Aufl., München: C. H. Beck.
- Frommel, Monika (2013), in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), *Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 3. Aufl., Baden-Baden: Nomos, § 177.
- Geppert, Klaus (2006), *Die Nötigung (§ 240 StGB)*, Jura, S. 31-41.
- Gössel, Karl Heinz (2005), *Das neue Sexualstrafrecht*, Berlin: De Gruyter Recht.
- Gössel, Karl Heinz/Dölling, Dieter (2004), *Strafrecht, Besonderer Teil 1*, 2. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.
- Günther, Hans-Ludwig (1976), *Zur Kombination von Täuschung und Drohung bei Betrug und Erpressung*, ZStW 88, S. 960-977.
- Heinrich, Bernd (2014), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillenkamp, Thomas (2003), *Unverstand und Aberglaube*, in: Amelung (Hrsg.), *Strafrecht, Biorecht, Rechtsphilosophie (Festschrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag)*, Heidelberg: Müller, S. 135-151.
- Hörnle, Tatjana (2010), in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), *Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch*, 12. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter, § 177.
- (2015), *Warum § 177 Abs. 1 StGB durch einen neuen Tatbestand ergänzt werden sollte*, ZIS, S. 206-216.
- (2015), *Wie § 177 StGB ergänzt werden sollte*, GA, S. 313-328.
- Isfen, Osman (2015), *Zur gesetzlichen Normierung des entgegenstehenden Willens bei Sexualdelikten*, ZIS, S. 217-233.
- Jakobs, Günther (1991), *Strafrecht, Allgemeiner Teil* (1983), 2. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter.
- Kindhäuser, Urs (2012), *Strafrecht, Besonderer Teil 1*, 5. Aufl., Baden-

Baden: Nomos.

—— (2013), Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar (LPK-StGB), 5. Aufl., Baden-Baden: Nomos.

Krey, Volker (1977), Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, Eine Einführung in die Problematik des Analogieverbots, Berlin: Duncker Humblot.

Krey, Volker/Hellmann, Uwe/Heinrich, Manfred (2012), Strafrecht, Besonderer Teil, Band 1, 15. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.

Lackner, Karl/Kühl, Kristian (2011), Strafgesetzbuch, 27. Aufl., München: C. H. Beck.

Laubenthal, Klaus (2012), Handbuch Sexualstraftaten, Die Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Heidelberg: Springer.

Lenckner, Theodor/Sternberg-Lieben, Detlev (2014), in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., München: C. H. Beck, Vorbem. §§ 32 ff.

Maurach, Reinhard/Schroeder, Friedrich-Christian/Maiwald, Manfred (2003), Strafrecht, Besonderer Teil, Teilband 1, 9. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.

Murmann, Uwe (2013), Grundkurs Strafrecht, 2. Aufl., München: C. H. Beck.

Otto, Harro (2002), Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte, 5. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter.

Perron, Walter/Eisele, Jörg (2014), in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., München: C. H. Beck, § 177.

Renzikowski, Joachim (1999), Das Sexualstrafrecht nach dem 6. Strafrechtsreformgesetz – 1. Teil, NstZ, S. 377-385.

—— (2005), in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, München: C. H. Beck, § 177.

Rönnau, Thomas (2001), Willensmängel bei der Einwilligung im

- Strafrecht, Tübingen: Mohr Siebeck.
- (2002), Die Einwilligung als Instrument der Freiheitsbetätigung, Jura, S. 595-598.
- (2002), Voraussetzungen und Grenzen der Einwilligung im Strafrecht, Jura, S. 665-675.
- (2006), in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, München: C. H. Beck, Vor § 32.
- Rosenau, Henning (2009), in: Satzger/Schmitt/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, Köln: Carl Heymanns, Vor §§ 32 ff.
- Roxin, Claus (2006), Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band 1, 4. Aufl., München: C. H. Beck.
- Samson, Erich (1978), Grundprobleme des Betrugstatbestandes (1. Teil), JA, S. 469-475.
- (1978), Grundprobleme des Betrugstatbestandes (2. Teil), JA, S. 564-570.
- (1985), Strafrecht II, 5. Aufl., Frankfurt am Main: Alfred Metzner Verlag.
- Sternberg-Lieben, Detlev (1997), Die objektiven Schranken der Einwilligung im Strafrecht, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Sternberg-Lieben, Detlev/Sternberg-Lieben, Irene (2012), Vorsatz im Strafrecht, JuS, S. 976-980.
- Toepel, Friedrich (2010), in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch, 3. Aufl., Baden-Baden: Nomos, § 240.
- Träger, Ernst/Altwater, Gerhard (2001), in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 12. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter, § 240.
- Tsai, Sheng-Wei (2006), Zur Problematik der Tatbestandsalternativen im Strafrecht—Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom strafrechtlichen

Tatbestandsmerkmal, Berlin: Duncker Humblot.

Welzel, Hans (1969), Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl., Berlin: Walter de Gruyter.

Wessels, Johannes/Beulke, Werner/Satzger, Hellmut (2014), Strafrecht, Allgemeiner Teil, 44. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.

Wessels, Johannes/Hettinger, Michael (2010), Strafrecht, Besonderer Teil 1, 34. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.

Wessels, Johannes/Hillenkamp, Thomas (2010), Strafrecht, Besonderer Teil 2, 33. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.

Wolters, Gereon (2009), in: Satzger/Schmitt/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, Köln: Carl Heymanns, § 177.

Wolters, Gereon/Horn, Eckhard (2013), in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 8. Aufl., Köln: Carl Heymanns, § 177.

Ziegler, Theo (2012), in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Strafgesetzbuch (Beck'scher Online Kommentar), Berlin: C. H. Beck, § 177.

Forcible Means in the Crime of Forced Sexual Intercourse

*Sheng-Wei Tsai**

Abstract

The amendment of Chapter 16 of Taiwan Criminal Code in 1999 is a landmark change. One of the major changes is the actus reus of Article 221(1), which replaced “unable to render resistance” with “any other means that against the victim’s will”. Although this amendment highlights the nature of the legal interest Article 221(1) intends to protect, it has initiated various interpretative difficulties. The omnibus clause should apply to situations where the perpetrator uses a pre-existing condition to coerce a sexual intercourse. Such an action is comparable to a forced sexual intercourse. Both are illegal because they violate the victim’s will.

KEYWORDS: forced sexual intercourse, rape, forcible rape, against the victim’s will, coercion, threat, statutory rape.

* Associate Professor, College of Law, National Taipei University.